

CAPÍTULO 2

SUJETOS DEL DERECHO INTERNACIONAL

Silvina S. González Napolitano y Milton Fellay

1. Sujetos y actores del derecho internacional

La cuestión de los sujetos y actores del derecho internacional se encuentra entre las más debatidas por los académicos. Basta observar el tratamiento disímil que se le da en los distintos manuales de derecho internacional y otras obras específicas sobre el tema. Desde la teoría, aun compartiendo una misma definición de "sujeto de derecho internacional", los internacionalistas no coinciden en la enumeración de todas las entidades *no estatales* que califican de sujetos. Algunos incluso se refieren a una misma entidad pero con diversas denominaciones. A ello se suma la complicación de identificar con claridad en la práctica a otros actores del ámbito internacional.

Podría decirse que en la comunidad internacional —en sentido amplio¹— hay pluralidad de sujetos y de actores. Siguiendo la clásica definición de *sujeto de derecho* (como todo ente capaz de adquirir derechos o contraer obligaciones; o centro de imputación de normas), los *sujetos del derecho internacional* son todos aquellos entes que poseen capacidad jurídica para adquirir derechos internacionales y/o contraer obligaciones internacionales, o que son centro de imputación de normas internacionales.

En este capítulo asumiremos que todo sujeto de derecho internacional goza de personalidad jurídica internacional, pese a que los juristas tampoco se han puesto de acuerdo en cuanto a si la subjetividad internacional y la personalidad internacional son conceptos equivalentes o distintos, es decir, si todos los sujetos del derecho internacional son personas jurídicas internacionales y viceversa, o si una de estas categorías es más amplia que la otra².

También asumiremos que no todo sujeto de derecho internacional tiene capacidad para crear por sí mismo normas internacionales, lo que no les impide a los sujetos que no posean esta capacidad ser de todas formas centro de imputación de normas internacionales creadas por otros sujetos. Esto implica, entonces, que la capacidad de crear derecho o de legislar no es una condición *sine qua non* para la atribución de subjetividad internacional.

Se puede afirmar que, al gozar de derechos, los sujetos del derecho internacional podrán efectuar un reclamo internacional en caso de violación. No obstante, algunos sujetos poseen una capacidad para actuar limitada, como veremos más abajo, y no pueden reclamar por sí mismos en el plano internacional. De igual forma, en caso de poseer obligaciones internacionales, los sujetos serán pasibles de responsabilidad internacional ante su incumplimiento o en

¹ La expresión "comunidad internacional" también es utilizada en un sentido más estricto para hacer alusión a los Estados que la integran ("comunidad internacional de Estados"). Así, el artículo 53 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados (1989) define a la norma imperativa de derecho internacional general como "una norma aceptada y reconocida por la comunidad internacional de Estados en su conjunto".

² Cfr. Feldman, David, "International Personality", *R.C.A.D.I.*, vol. 121 (1985-II), p. 351; Portmann, Roland, *Legal Personality in International Law*, Cambridge University Press, Cambridge, 2010.

el supuesto de causar un daño a otro sujeto. Así, reclamación internacional y responsabilidad internacional funcionarían como consecuencias de la subjetividad internacional.

El resto de los entes (o entidades) que no poseen subjetividad internacional, pero que cumplen un rol destacado en el ámbito internacional –por ejemplo, llamando la atención de los Estados y organizaciones internacionales respecto de la necesidad de regular ciertas cuestiones o haciendo públicas algunas violaciones del derecho internacional–, simplemente son denominados “actores”. La mayoría de los juristas incluye dentro de esta categoría a algunas organizaciones no gubernamentales, en particular las que desempeñan funciones más allá de las fronteras de los Estados en los que fueron creadas. Sin embargo, como se observará *infra*, podría haber razones a favor de la personalidad internacional de las organizaciones no gubernamentales.

Un simple actor se podría convertir en sujeto del derecho internacional en el momento en que los Estados adopten (o reconozcan que existe) una norma internacional que regule específicamente su conducta (o la de toda la clase genérica a la que pertenece), como una categoría diferenciada del resto de los sujetos ya reconocidos.

En la actualidad existen varias categorías o clases de sujetos internacionales. Puede hablarse de sujetos “originarios” y “derivados”, todos ellos con distintas capacidades para actuar. Algunos poseen capacidad para celebrar tratados internacionales y/o entablar relaciones diplomáticas, mientras que otros no poseen ninguno de esos poderes, pero pueden reclamar por sí mismos ante órganos internacionales frente a las violaciones de sus derechos. Otros, en cambio, gozan de derechos sustantivos, pero no de derechos procedimentales. Ello ha llevado a los doctrinarios a hablar de “personalidad jurídica internacional plena” y “personalidad jurídica internacional limitada” y a distinguir entre “capacidad jurídica internacional” y “capacidad para actuar”. Tal como ha señalado la Corte Internacional de Justicia en su afamada Opinión Consultiva sobre *Reparación de Perjuicios* –la cual desarrollaremos más adelante–, “Los sujetos de derecho, en un sistema jurídico, no son necesariamente idénticos en cuanto a su naturaleza o a la extensión de sus derechos, y su naturaleza depende de las necesidades de la comunidad”.⁴

Si bien en los orígenes del derecho internacional el Estado era el único sujeto reconocido⁵, por lo que califica como “sujeto originario”, con el transcurso del tiempo –principalmente a partir del siglo XVIII– fueron surgiendo otros entes o entidades no estatales, a quienes denominaremos “sujetos derivados”, puesto que su subjetividad deriva de la voluntad de los Estados, la cual se manifiesta, por ejemplo, a través de tratados internacionales o de la propia práctica (derecho consuetudinario). Dentro de esta clase, adoptando también un criterio amplio, podemos identificar las siguientes categorías:

- las organizaciones internacionales gubernamentales y otros organismos;
- los pueblos que luchan por la autodeterminación;
- los grupos beligerantes;
- los individuos;
- los inversores extranjeros;
- ciertas organizaciones no gubernamentales.

Algunos sujetos derivados, a quienes se los suele denominar “sujetos atípicos” o “*sui generis*”, son únicos en su especie. Pueden incluirse los siguientes:

- la Iglesia Católica;
- la Soberana Orden de Malta;
- el Comité Internacional de la Cruz Roja.

3 Walter, Christian, “Subjects of International Law” (2009), en *Max Planck Encyclopedia of Public International Law*, <http://www.mpepil.com>, párrs. 21-23.

4 *Reparación de perjuicios sufridos al servicio de las Naciones Unidas*, CIJ, Opinión Consultiva, 11/04/1949, ICJ Reports 1949, p. 178 (traducción libre).

5 Un conocido tratado sobre el Derecho Internacional afirmaba en su edición de 1920: “[...] pero además de la Liga de las Naciones, los Estados soberanos exclusivamente son Personas Internacionales, es decir sujetos de Derecho Internacional”, Oppenheim, Lassa F. L., *International Law: A Treatise*, Longmans, Londres, 3.ª edic., 1920, p. 125 (traducción libre).

Dado que la comunidad internacional está en constante evolución, con el correr del tiempo se van perfilando nuevos sujetos y actores. Sin embargo, como el derecho no es una ciencia exacta, en ocasiones resulta difícil identificar con certeza la naturaleza jurídica de algunas entidades o sus capacidades en derecho internacional, así como afirmar si ciertos actores han alcanzado la categoría de sujetos del derecho internacional. Dentro de estas categorías discutibles, sobre las cuales los juristas sostienen diversas interpretaciones, podemos mencionar –*inter alia*– a los pueblos indígenas u originarios, la denominada “sociedad civil” y la “humanidad” y/o las “generaciones futuras”.

Por otro lado, no podemos dejar de señalar que en la actualidad ciertos doctrinarios han comenzado a criticar la mismísima noción de “sujetos” por considerar que no constituye un aporte al desarrollo del derecho internacional⁶. Entre ellos, la profesora Higgins, quien se refiere a los entes que se desenvuelven en el plano internacional bajo el mote de participantes⁷. Así, señala, refiriéndose a la doctrina de los sujetos, que “hemos construido una prisión intelectual de nuestra propia elección y después la hemos declarado una limitación inalterable”. La ex jueza Higgins no está sola a la hora de criticar la noción de sujetos⁸.

2. Los Estados

Los Estados son sujetos originarios del derecho internacional y los que poseen mayores competencias, capacidades o poderes para actuar en el plano internacional, es decir que gozan de plena personalidad jurídica internacional.

Un famoso tratado internacional adoptado en el contexto americano –la Convención de Montevideo sobre Derechos y Deberes de los Estados (1933)– se ocupó de definir al Estado como una “persona de derecho internacional”¹⁰.

Existen diversos criterios o elementos para determinar si una entidad es un “Estado”. En este sentido, la mencionada Convención de Montevideo señala los siguientes:

- población permanente,
- territorio determinado,
- gobierno,
- capacidad de entrar en relaciones con los demás Estados.

Ciertos autores agregan, además, otros criterios, como gozar de independencia o soberanía¹¹ y permanencia¹². Algunos mencionan también la nacionalidad, aunque otros no la consideran un elemento necesario¹³, sino sobreviviente del surgimiento del Estado. Si bien en alguna época se discutía si el reconocimiento de otros Estados era una condición necesaria para la existencia de un Estado (teoría constitutiva), como se tratará en el capítulo 18, la Convención de Montevideo dispuso en su artículo 3 que “La existencia política del Estado es independiente de su reconocimiento por los demás Estados” (teoría declarativa).

6 Société Française pour le Droit International, *Colloque du Mans: Le Sujet en Droit International*, Pedone, París, 2005.

7 Higgins, Rosalyn, *Problem and Process: International Law and How We Use It*, Clarendon Press, Oxford, 2007, pp. 39-55.

8 *Ibid.*, p. 49.

9 En ese sentido, ver Klabbers, Jan, *An Introduction to International Institutional Law*, Cambridge University Press, Cambridge, 2002, p. 43; Clapham, Andrew, “Thinking Responsibility about the Subjects of Subjects”, en *Human Rights Obligations of Non-State Actors*, Clapham, Andrew (ed.), Oxford University Press, Oxford, 2006, pp. 59-83; Nijman, James E., “Paul Ricoeur and International Law: Beyond ‘The End of the Subject’. Towards a Reconceptualization of International Legal Personality”, *Leiden Journal of International Law*, vol. 20 (2007), pp. 25-64, entre otros.

10 Artículo 1 de la Convención de Montevideo sobre Derechos y Deberes de los Estados, firmada el 26/12/1933 en la Séptima Conferencia Internacional de los Estados Americanos; entró en vigor el 26/12/1934. La República Argentina firmó la Convención pero no la ratificó.

11 Crawford, James, “State” (2012), en *Max Planck Encyclopedia of Public International Law*, <http://www.mpepil.com>, párrs. 26 y 40.

12 *Ibid.*, párr. 42.

13 *Ibid.*, párrs. 21 y 44.

En cuanto a la población, cabe aclarar que debe tener permanencia, sin importar su densidad, la cual dependerá, en cierta medida, del tamaño del territorio y demás características geográficas.

Con relación al territorio, es dable destacar que, si bien es un elemento necesario, no importa si se encuentra total o parcialmente en disputa con otro u otros Estados¹⁴. Por eso mismo tampoco tiene relevancia si parte de la frontera se encuentra todavía sin delimitar. Asimismo, no interesa la extensión que tenga. En efecto, existen los denominados "micro Estados", de reducida extensión territorial, lo cual no ha impedido el reconocimiento de su calidad estatal y su ingreso a organizaciones internacionales gubernamentales¹⁵. Pueden citarse como ejemplo Andorra, Liechtenstein, Mónaco y San Marino¹⁶.

Si bien el Estado es una entidad territorial, no todo sujeto del derecho internacional que posea territorio propio se transforma por ello en un Estado.

Acerca del gobierno, se requiere que sea efectivo, capaz de ejercer sus poderes jurisdiccionales y de control sobre la población y el territorio. Cuando un Estado ya no reúne estas condiciones, comúnmente es calificado de "Estado fallido", situación que genera preocupación en la comunidad internacional¹⁷. En principio, no tiene relevancia para el derecho internacional la forma de gobierno adoptada por cada Estado¹⁸.

Sobre la capacidad para entablar relaciones con otros Estados, con acierto se señala que, si bien es un criterio útil para determinar la existencia de una entidad estatal, no es una prerrogativa exclusiva de los Estados, puesto que existen otros sujetos del derecho internacional que tienen capacidad para mantener —y de hecho lo hacen— relaciones diplomáticas con los Estados¹⁹.

En virtud de la soberanía que poseen los Estados, se reconoce que en el ámbito interno ejercen de manera exclusiva poder de imperio sobre su territorio y, en el ámbito externo, se afirma su independencia respecto de otros Estados, a los que se sitúa en un plano de igualdad. De ahí la afirmación de los principios de igualdad soberana y no intervención en los asuntos internos de otros Estados, que se tratan en el capítulo 36, y el reconocimiento de ciertas inmunidades del Estado (de jurisdicción y de ejecución), que se desarrollan en el capítulo 37.

Los Estados tienen plena competencia para actuar en el plano internacional, como se analiza en los capítulos siguientes de esta obra. Además de mantener relaciones diplomáticas con otros Estados y algunas entidades no estatales (*jus legationem*), los Estados, como sujetos del derecho internacional, tienen derecho a celebrar tratados²⁰ (*jus tractum/jus tractatus*) y generar normas consuetudinarias junto a otro u otros Estados. Pueden adquirir derechos y contraer obligaciones internacionales, siendo pasibles de responsabilidad internacional en caso de incumplimiento.

¹⁴ Ibid., párr. 19.

¹⁵ Para mayor detalle ver Grant, Thomas, "Micro States" (2010), en *Max Planck Encyclopedia of Public International Law*, <http://www.mpepil.com>; Murray, Fiona, "Micro-States (Andorra, Monaco, San Marino and the Vatican City)", en *The European Union and its neighbours: a legal appraisal of the EU's policies of stabilisation, partnership and integration*, Blockmans, Steven y Łasowski, Adam (eds.), T.M.C. Asser Press, La Haya, 2006, pp. 185-208.

¹⁶ Grant, Thomas, *op. cit.*, párr. 1. Algunos Estados cuestionan a los micro Estados por su limitada capacidad efectiva para interactuar con otros Estados. Si bien poseen representaciones diplomáticas en algunos Estados vecinos, no disponen de medios para mantener por sí mismos relaciones con todos los Estados (e con un buen número de ellos) (ibid., párr. 6).

¹⁷ Lax, Irene R., "A State of Failure: the Sacrosanctity of Sovereignty and the Perpetuation of Conflict in Weak and Failing States", *Temple International and Comparative Law Journal*, vol. 36, n.º 1 (2012), pp. 25-68; Thürer, Daniel, "Failing States" (2009), en *Max Planck Encyclopedia of Public International Law*, <http://www.mpepil.com>.

¹⁸ La Corte Internacional de Justicia ha dicho que "las orientaciones políticas internas de un Estado pertenecen a la competencia exclusiva de éste, siempre que, bien entendido, no violen una obligación de derecho internacional"; *Actividades militares y paramilitares en Nicaragua y contra Nicaragua*, C.I.J., Fallo, 21/11/1984, parágrafo 258 (traducción libre).

¹⁹ Crawford, James, *op. cit.*, párr. 25.

²⁰ Por ejemplo, el artículo 6 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados (1969) dispone: "Todo Estado tiene capacidad para celebrar tratados".

Existen supuestos de Estados *dependientes* —como el Principado de Mónaco—, es decir, que en algunas materias o competencias se han subordinado a otros Estados, lo cual no significa necesariamente que hayan perdido su condición de sujetos del derecho internacional. Así, se afirma que "El Estado dependiente continúa siendo un sujeto de derecho internacional", pero "si la dependencia es tal que el Estado dependiente deja de ser sujeto de todo derecho y obligación en el plano internacional, entonces pierde la calidad de persona del derecho de gentes"²¹.

Por último, los Estados gozan de personalidad internacional independientemente de su organización política. Si bien los académicos han discutido al respecto²², consideramos que las subdivisiones políticas (provincias, cantones, etc.) de un Estado federal²³ no son sujetos de derecho internacional, aunque estén autorizadas por la legislación interna del Estado para actuar directamente en el plano internacional. Así, la ya citada Convención de Montevideo previó en el artículo 2 que "El Estado federal constituye una sola persona ante el Derecho Internacional". En ese mismo sentido, el Proyecto sobre Responsabilidad internacional del Estado elaborado por la Comisión de Derecho Internacional de las Naciones Unidas dispone que el comportamiento de un órgano del Estado se considera un hecho de ese Estado según el derecho internacional a los efectos de la responsabilidad internacional por hechos internacionalmente ilícitos, "cualquiera que sea su posición en la organización del Estado y tanto si pertenece al gobierno central como a una división territorial del Estado"²⁴.

3. Entidades de naturaleza no estatal

El término entidades de naturaleza no estatal engloba a todos aquellos participantes de la comunidad internacional distintos de los Estados. La mayoría, pero no todas ellas, poseen alguna forma de capacidad jurídica en el derecho internacional. Esta capacidad dependerá de cada una de las entidades en cuestión y de los derechos y obligaciones que se les hayan asignado en el ordenamiento jurídico internacional²⁵. La concepción clásica del derecho internacional solo les atribuye subjetividad internacional a un reducido número de entidades no estatales²⁶, sin embargo, el derecho internacional contemporáneo ha dejado atrás esta limitación. A continuación analizaremos las entidades de naturaleza no estatal más relevantes para el ordenamiento jurídico internacional y discutiremos la posibilidad de que estas puedan ser consideradas sujetos del derecho internacional, de conformidad con la noción de sujeto que hemos brindado.

3.1. Las organizaciones internacionales y otros organismos

Con carácter previo, se impone hacer algunas distinciones terminológicas, en particular entre expresiones tales como "organizaciones internacionales" y "órganos internacionales". A veces la distinción entre ellos no es clara, incluso se suelen utilizar términos más genéricos como "instituciones internacionales" u "organismos internacionales", que comprenden tanto a las organizaciones internacionales como a sus órganos, o a los órganos independientes creados por tratados internacionales, que *stricto sensu* no son organizaciones internacionales (por ejemplo, los órganos de vigilancia en materia de derechos humanos como el Comité de Derechos Humanos).

Díez de Velasco define a las organizaciones internacionales de la siguiente manera: "Asociaciones voluntarias de Estados establecidas por acuerdo internacional, dotadas de órganos

²¹ Armas Párrer, Frida; Barberis, Julio y Querol, María, *Sujetos del derecho de gentes*, Editorial Ábaco de Rodolfo Depalma, Buenos Aires, 1999, p. 37.

²² Barberis, Julio, "Nouvelles questions concernant la personnalité juridique internationale", *R.C.A.D.I.*, vol. 178 (1988), pp. 187-188; Feldman, David, *op. cit.*, p. 377 y ss.

²³ Distinto sería el caso de una confederación de Estados.

²⁴ Proyecto de artículos de la CDI sobre la Responsabilidad del Estado por hechos internacionalmente ilícitos, Doc. A/CN.4/L.602/Rev. 1, 26/07/2001 (disponible en <http://www.un.org/law/ilco>), art. 4(1).

²⁵ Wagner, Markus, "Non-State Actors" (2009), en *Max Planck Encyclopedia of Public International Law*, <http://www.mpepil.com>, párr. 1.

²⁶ Ibid., párr. 5.

permanentes, propios e independientes, encargados de gestionar unos intereses colectivos y capaces de expresar una voluntad jurídicamente distinta de la de sus miembros²⁷. De esta definición tradicional se derivan los siguientes caracteres:

- están compuestas por Estados;
- son creadas a través de un tratado internacional;
- tienen por finalidad gestionar intereses colectivos;
- poseen una estructura orgánica permanente e independiente;
- poseen autonomía jurídica.

La Organización de las Naciones Unidas (ONU), la Organización de Estados Americanos (OEA) y el Consejo de Europa son, por ejemplo, organizaciones que encuadran en aquella definición.

Sin embargo, en la actualidad, si bien las características antes señaladas se presentan en la mayoría de las organizaciones, no se dan necesariamente en todas ellas. Por ello la definición tradicional ha sido objeto de cuestionamientos. En tal sentido, Klabbers plantea los problemas que surgen al tratar de definir qué es exactamente una organización internacional y sostiene que resulta difícil establecer una definición omnicompreensiva, teniendo en cuenta las variantes que se pueden presentar²⁸. Con acierto, este jurista señala que algunas veces el estatus de ciertas entidades ha sido discutido por la doctrina internacional²⁹, como el Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio (GATT) –previo a la constitución de la Organización Mundial del Comercio (OMC)–, la Unión Europea (UE) –antes del Tratado de Lisboa³⁰– o la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE).

En cuanto a la creación y composición de las organizaciones internacionales, Klabbers advierte que no siempre son creadas únicamente por Estados y no siempre son estos los únicos que las integran. Así, hay organizaciones internacionales que son miembros de otras organizaciones internacionales –y hasta miembros fundadores–, como la Comunidad Europea, que era miembro de la FAO y miembro fundador de la OMC. Cita incluso el caso de una organización internacional creada exclusivamente por varias organizaciones internacionales (tal el caso del Joint Vienna Institut, instituido en 1994 por distintas organizaciones internacionales financieras –entre ellas el FMI y la OCDE– para asistir a Estados europeos del Este en su transición hacia economías de mercado)³¹.

Respecto al modo de creación, aunque las organizaciones internacionales son establecidas por un acto internacional, puede no ser un tratado, sino un acto unilateral de otra organización internacional, como una resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Según Klabbers, tal sería el caso de la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial (ONUDI)³² y del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF)³³, aunque este último generalmente es visto como un órgano más que como una organización.

También se ha recurrido a otro método –tampoco libre de críticas– para tratar de identificar a las organizaciones internacionales: por el derecho que las regula. Si están regidas por el derecho internacional, se habla de una organización internacional en sentido propio, es decir, una organización intergubernamental. Si están regidas por el derecho interno, se habla de una organización no gubernamental (ONG)³⁴.

27 Díez de Velasco, Manuel, *Las Organizaciones Internacionales*, Tecnos, Madrid, 11.ª edic., 1999, p. 44.

28 Klabbers, Jan, *op. cit.*, p. 7.

29 *Ibid.*, pp. 10-11 y 14.

30 Previo a la adopción del Tratado de Lisboa (2007), diversos autores ponían énfasis en que la Unión Europea no había sido dotada de personalidad jurídica y la concebían como una entidad híbrida; ver, por ejemplo, Boulouis, Jean, *Droit institutionnel de l'Union européenne*, Montchrestien, Paris, 6.ª edic., 1997, p. 46; ver también el prólogo de Antonio Remiro Brotons en Díez-Hochleitner, Javier, *La posición del Derecho Internacional en el Ordenamiento comunitario*, McGraw Hill, Madrid, 1998, p. xiii. Con el Tratado de Lisboa la Unión Europea adquirió personalidad jurídica propia.

31 Klabbers, Jan, *op. cit.*, p. 9, nota al pie 26.

32 Ver Resolución 36/96 de la Asamblea General, 13/12/1979.

33 Klabbers, Jan, *op. cit.*, p. 11.

34 *Ibid.*, p. 8.

Por su parte, la Comisión de Derecho Internacional de las Naciones Unidas, en el marco del proyecto sobre responsabilidad internacional de las organizaciones internacionales, elaboró la siguiente definición, que también ha recibido críticas³⁵:

A los efectos del presente proyecto de artículos, por "organización internacional" se entenderá una organización instituida por un tratado u otro instrumento regido por el derecho internacional y dotada de personalidad jurídica internacional propia. Las organizaciones internacionales pueden contar entre sus miembros, además de los Estados, otras entidades³⁶.

Si bien, como se mencionó en el capítulo 1 de esta obra, en el siglo XIX surgen las uniones administrativas, es en el siglo XX cuando aparece la primera organización internacional gubernamental: la Sociedad de las Naciones –o Liga de las Naciones–, creada en 1919 por el Pacto de las Sociedades de las Naciones. Dicha organización fue sucedida por la Organización de las Naciones Unidas, creada por la Carta de San Francisco (1945), como se verá en el próximo capítulo.

En la actualidad existen distintas clases de organizaciones internacionales, como, por ejemplo: universales³⁷, regionales³⁸ o subregionales³⁹, binacionales⁴⁰, de fines generales⁴¹ o específicos⁴², supranacionales⁴³, etc.

Los organismos especializados de las Naciones Unidas son organizaciones intergubernamentales creadas por un tratado entre Estados, vinculadas al sistema de las Naciones Unidas⁴⁴ y con los fines determinados en su instrumento constitutivo⁴⁵. Son organismos especializados de las Naciones Unidas: la Organización Mundial de la Salud (OMS), la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la Unión Postal Universal (UPU), la Organización Mundial del Comercio (OMC), el Fondo Monetario Internacional (FMI), entre otros.

Las organizaciones internacionales poseen una personalidad jurídica distinta y separada de sus miembros. Al igual que los Estados, gozan de inmunidad de jurisdicción, y sus funcionarios, de privilegios e inmunidades. Además, a muchas de ellas se les ha reconocido la capacidad para crear normas internacionales (por ejemplo, a través de actos internos –resoluciones, decisiones, reglamentos– o de tratados internacionales), como se desarrolla en el capítulo 13, y la capacidad de reclamar internacionalmente en caso de violación a sus derechos o a los de sus funcionarios⁴⁶. Pueden también incurrir en responsabilidad internacional en caso de incumplimiento de obligaciones internacionales, como se verá en el capítulo 17.

35 Schmalenbach, Kirsten, "International Organizations or Institutions, General Aspects" (2008), en *Max Planck Encyclopedia of Public International Law*, <http://www.mpepil.com>, párr. 8.

36 Informe de la Comisión de Derecho Internacional sobre la labor realizada en su 64.ª período de sesiones, U.N. GAOR, 57.ª Ses., U.N. Doc A/Res/57/21 (2002).

37 Por ejemplo, la Organización de las Naciones Unidas, la Organización Mundial del Comercio, etc.

38 Tal el caso de la Organización de Estados Americanos, el Consejo de Europa, la Unión Europea, la Unión Africana, etc.

39 Por ejemplo, el Mercosur.

40 Como la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande y la Comisión Administradora del Río Uruguay.

41 Puede citarse la Organización de las Naciones Unidas o la Organización de Estados Americanos.

42 Por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud, la Organización Internacional del Trabajo, entre otras.

43 Tal el caso de la Unión Europea.

44 Cfr. Carta de las Naciones Unidas, artículos 57-59 y 63. El artículo 63 dispone:

1. El Consejo Económico y Social podrá concertar con cualquiera de los organismos especializados de que trata el Artículo 57, acuerdos por medio de los cuales se establezcan las condiciones en que dichos organismos habrán de vincularse con la Organización. Tales acuerdos estarán sujetos a la aprobación de la Asamblea General.

2. El Consejo Económico y Social podrá coordinar las actividades de los organismos especializados mediante consultas con ellos y haciéndoles recomendaciones, como también mediante recomendaciones a la Asamblea General y a los Miembros de las Naciones Unidas.

45 Para mayor información ver Klein, Eckart, "United Nations, Specialized Agencies" (2010), en *Max Planck Encyclopedia of Public International Law*, <http://www.mpepil.com>.

46 La doctrina se refiere, asimismo, a otros poderes implícitos que tienen las organizaciones internacionales; ver Blokker, Niels M., "International Organizations or Institutions, Implied Powers" (2010), en *Max Planck Encyclopedia of Public International Law*, <http://www.mpepil.com>.

En cuanto a la personalidad jurídica de las organizaciones internacionales, y de las Naciones Unidas en particular, no puede dejar de mencionarse la Opinión Consultiva emitida por la Corte Internacional de Justicia en 1949, respecto de la *Reparación de perjuicios sufridos al servicio de las Naciones Unidas*. La situación que dio origen al pedido de esta Opinión Consultiva por parte de la Asamblea General fue el asesinato del Conde Folke Bernadotte –de nacionalidad sueca–, quien en 1948 había sido enviado por las Naciones Unidas como mediador a Palestina durante el conflicto árabe-israelí, y fue asesinado, junto con un observador de las Naciones Unidas –el coronel francés André Sérot–, por un comando israelí⁴⁷.

Por ello, la Asamblea General realizó la siguiente consulta a la CIJ:

- I. En el caso de que un agente de las Naciones Unidas, en el desempeño de sus funciones, sufra un daño en circunstancias tales que impliquen la responsabilidad de un Estado, ¿tienen las Naciones Unidas competencia para entablar una reclamación internacional contra el gobierno de jure o de facto responsable, a fin de obtener la reparación por los daños causados: a) a las Naciones Unidas, b) a la víctima o a sus causahabientes?
- II. En caso de respuesta afirmativa sobre el inciso b) del punto I, ¿cómo debe conciliarse la acción de las Naciones Unidas con los derechos a que sea acreedor el Estado donde procede la víctima?

Antes de responder acerca de la competencia para entablar una reclamación internacional –que interpreta como la capacidad que tienen normalmente los Estados para recurrir a métodos tales como la protesta, una solicitud de investigación, la negociación o, de permitirse, el sometimiento de la cuestión ante un tribunal–⁴⁸, la Corte se plantea si las Naciones Unidas tienen personalidad internacional, es decir, si esta entidad puede ser beneficiaria de obligaciones de parte de los Estados miembros.

La Corte considera que en un sistema jurídico los sujetos de derecho no son necesariamente idénticos en cuanto a la extensión de sus derechos, cuestión que depende de las necesidades de la comunidad⁴⁹. Si bien la Carta de las Naciones Unidas no lo establece, la CIJ entiende que, para poder cumplir con sus objetivos –teniendo la importante misión de mantener la paz y la seguridad internacionales–, es indispensable que la Organización de las Naciones Unidas posea personalidad internacional. Las Naciones Unidas no son simplemente un centro que armoniza los esfuerzos de las naciones para cumplir con fines comunes –como reza el artículo 1(4) de la Carta–, sino que está dotada de órganos y tiene una misión propia. Además, sus miembros deben prestarle asistencia en toda acción que emprenda, de conformidad con el artículo 2(5) de la Carta, y han aceptado cumplir con las resoluciones del Consejo de Seguridad y autorizado a la Asamblea General a emitir recomendaciones, entre otros. En consecuencia, la Corte califica a las Naciones Unidas como “el tipo más elevado de organización internacional”⁵⁰ y concluye que es una persona internacional. Si bien posee una amplia capacidad de actuar en el plano internacional, aclara que esto no equivale a decir que se trate de un “super-Estado”, sino que simplemente “significa que la organización es un sujeto de derecho internacional, que tiene capacidad para ser titular de derechos y deberes internacionales y que tiene capacidad para asegurarse esos derechos por vía de una reclamación internacional”⁵¹.

La Corte examina si entre los derechos internacionales de que goza la Organización se encuentra el de presentar una reclamación internacional para obtener reparación de un Estado por los daños causados a un agente de la Organización en el ejercicio de sus funciones y responde a ello afirmativamente, sin importar si el Estado es o no miembro de las Naciones

47 Ver d'Argent, Pierre, “Reparation for Injuries Suffered in the Service of the United Nations (Advisory Opinion)” (2010), en *Max Planck Encyclopedia of Public International Law*, <http://www.mpepl.com>, párr. 1.

48 *Reparación de perjuicios sufridos al servicio de las Naciones Unidas*, CIJ, Opinión Consultiva, 11/04/1949, ICJ Reports 1949, p. 177.

49 *Ibid.*, p. 178 (traducción libre).

50 *Ibid.*, p. 179.

51 *Ibid.* (traducción libre).

Unidas, ya que los que son miembros han creado una entidad dotada de una personalidad internacional objetiva y no solo de la personalidad reconocida por ellos⁵².

Para analizar si puede entablar una reclamación internacional con miras a obtener reparación por los daños causados, no a la propia Organización, sino a la víctima o a sus causahabientes, la Corte hace un paralelo con la institución de la protección diplomática⁵³, que permite a los Estados reclamar por sus nacionales. Si bien las Naciones Unidas no tienen un vínculo de nacionalidad con sus agentes, es preciso que estos gocen de una protección adecuada, debido a las misiones importantes que deben cumplir en regiones problemáticas del mundo al servicio de la Organización⁵⁴. Por ello, la Corte afirma que la ONU está capacitada para ejercer una “protección funcional” de sus agentes.

Por último, en cuanto a la segunda cuestión planteada por la Asamblea General –es decir, cómo conciliar la acción de las Naciones Unidas con el derecho del Estado nacional de la víctima de reclamar por los daños causados a ella–, al no existir una norma de derecho internacional que otorgue prioridad a un reclamo sobre el otro, la Corte no ve razón por la cual las partes involucradas no puedan solucionar la cuestión inspiradas en la buena voluntad y el sentido común, destacando la asistencia que deben prestar los Estados miembros en virtud del artículo 2(5) de la Carta⁵⁵. Por otra parte, el riesgo de concurrencia entre protección diplomática del Estado de nacionalidad de la víctima y la protección funcional de la Organización puede reducirse o eliminarse mediante la adopción de una convención general o de acuerdos para cada caso particular. El hecho de que el agente posea la nacionalidad del Estado demandado tampoco constituye un obstáculo para el ejercicio de la protección funcional, ya que esta última no se basa en la nacionalidad, sino en la calidad de agente de la Organización⁵⁶.

Sobre la base de esta Opinión Consultiva, la Asamblea General, mediante la Resolución 365(IV) del 1 de diciembre de 1949, autorizó al secretario general a presentar un reclamo contra Israel por el asesinato del Conde Bernadotte. Se solicitaba a ese Estado que presentara una disculpa formal, que arrestara a los culpables y que procediera al pago de una indemnización por los daños causados a la Organización –ya que los familiares de la víctima no habían presentado reclamo alguno–. En 1950 Israel se disculpó y pagó la indemnización, por lo que la Organización se consideró satisfecha, aunque nunca llegó a arrestarse a los culpables⁵⁷.

A diferencia de lo que ocurre con la Carta de las Naciones Unidas, en muchos casos la personalidad jurídica de las organizaciones internacionales se contempla expresamente en su instrumento constitutivo, así como los poderes y capacidades que poseen.

Respecto de entes binacionales, el Estatuto del Río Uruguay⁵⁸ dispone en su artículo 50 que la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU) “gozará de personalidad jurídica para el cumplimiento de su cometido”. El Estatuto de la CARU agrega que “La Comisión es un Organismo Internacional con la capacidad jurídica necesaria para el cumplimiento de sus cometidos específicos”⁵⁹. En consecuencia, el personal de la CARU goza de “los privilegios e inmunidades diplomáticos necesarios para el ejercicio de sus funciones”⁶⁰.

En igual sentido, en lo que respecta a la Comisión Administradora del Río de la Plata (CARP), el Tratado del Río de la Plata y su Frente Marítimo⁶¹ dispone en su artículo 60 que “La Comisión Administradora gozará de personalidad jurídica para el cumplimiento de su

52 *Ibid.*, p. 186.

53 *Ibid.*, p. 181.

54 *Ibid.*, p. 188.

55 *Ibid.*, p. 186.

56 *Ibid.*

57 *Op. d'Argent, Pierre, op. cit.*, párr. 9.

58 Estatuto del Río Uruguay, suscripto por la República Argentina y la República Oriental del Uruguay el 26/02/1976.

59 Estatuto de la Comisión Administradora del Río Uruguay (1976), art. 2.

60 *Ibid.*, art. 21.

61 Tratado del Río de la Plata y su Frente Marítimo, suscripto por la República Argentina y la República Oriental del Uruguay el 19/11/1973.

cometido" y el artículo 2 del Estatuto de dicha Comisión⁶² estipula que "La Comisión es un Organismo Internacional con la capacidad jurídica necesaria para el cumplimiento de sus cometidos específicos". Uno de los poderes que se prevé expresamente es el de celebrar acuerdos⁶³. Los miembros de la Comisión gozan de "las inmunidades y privilegios diplomáticos necesarios para el ejercicio de sus funciones"⁶⁴.

Asimismo, respecto del Mercosur, el Protocolo de Ouro Preto⁶⁵, que establece la estructura institucional de dicho organismo, se refiere expresamente a su personalidad jurídica de la siguiente forma:

Capítulo II - Personalidad jurídica

Artículo 34: El Mercosur tendrá personalidad jurídica de Derecho Internacional.

Artículo 35: El Mercosur podrá, en el uso de sus atribuciones practicar todos los actos necesarios para la realización de sus objetivos, en especial contratar, adquirir o enajenar bienes muebles e inmuebles comparecer en juicio, conservar fondos y hacer transferencias.

Artículo 36: El Mercosur celebrará acuerdos de sede.

Además de las organizaciones internacionales, algunos órganos independientes creados por tratados internacionales —que no serían considerados organizaciones internacionales en el sentido de la definición tradicional— poseen personalidad jurídica internacional. Pueden citarse, por ejemplo, algunos tribunales penales internacionales, como la Corte Penal Internacional. En efecto, el Estatuto de Roma (1998)⁶⁶ dispone en el artículo 4(1) que "La Corte tendrá personalidad jurídica internacional. Tendrá también la capacidad jurídica que sea necesaria para el desempeño de sus funciones y la realización de sus propósitos". Entre sus poderes, la Corte Penal Internacional celebra acuerdos de sede con el Estado anfitrión⁶⁷ —la sede de la Corte se encuentra en la ciudad de La Haya, en los Países Bajos—.

3.2. Los pueblos que luchan por la autodeterminación y los movimientos de liberación nacional

Los movimientos de liberación nacional (en adelante, MLN) fueron admitidos como sujetos del ordenamiento jurídico internacional, principalmente como consecuencia de la aceptación por parte de la comunidad internacional del principio de autodeterminación de los pueblos (también conocido en la doctrina como el principio de libre determinación de los pueblos).

El surgimiento de los MLN se produjo particularmente a partir de la Segunda Guerra Mundial y la creación de la Organización de las Naciones Unidas. Estos movimientos surgieron principalmente en África, luego en Asia, en América del Sur, y en menor medida en Europa⁶⁸. A partir de su expansión desde África hacia el resto de los continentes, los MLN asimismo ampliaron sus objetivos, que originalmente se reducían a una lucha anticolonialista, para pasar a enfrentarse a regímenes racistas —como los movimientos que surgieron en Sudáfrica contra el *apartheid*— o conseguir un asentamiento territorial para un pueblo —el caso de la Organización para la Liberación de Palestina (OLP)— y la formación de un nuevo Estado.

Como sujetos del ordenamiento internacional tuvieron un lugar preponderante de 1960 a 1980. Hoy en día su importancia se ha visto reducida, en particular debido a que el proceso

62 Acuerdo entre el Gobierno de la República Argentina y el Gobierno de la República Oriental del Uruguay por el que se establece el Estatuto de la Comisión Administradora del Río de la Plata, suscrito el 15/07/1974.

63 Estatuto de la Comisión Administradora del Río de la Plata, art. 4(a).

64 *Ibid.*, art. 22.

65 Protocolo Adicional al Tratado de Asunción sobre la Estructura Institucional del Mercosur ("Protocolo de Ouro Preto"), suscrito por la República Argentina, la República Federativa del Brasil, la República del Paraguay y la República Oriental del Uruguay en la ciudad de Ouro Preto, 17/12/1994.

66 El Estatuto de Roma fue suscrito el 17/07/1998 y se encuentra en vigor desde el 01/07/2002.

67 Estatuto de Roma, art. 3(2).

68 Cassese, Antonio, *International Law*, Oxford University Press, Oxford, 2.ª edic., 2005, p. 140.

de descolonización en gran medida se ha completado⁶⁹ y, por otro lado, al reconocimiento de los pueblos en sí mismos como sujetos de este ordenamiento jurídico⁷⁰. Su calidad de sujetos del derecho internacional público reside en el reconocimiento de la comunidad internacional de los fines políticos de estos movimientos, ya sean estos la lucha por la descolonización, la opresión racial o la ocupación extranjera⁷¹.

Algunos juristas señalan que estos movimientos se caracterizan por tres notas puntuales: 1. el objetivo que persiguen en la lucha, esto es, la autodeterminación; 2. la calidad de quienes ejercen este derecho, es decir, los pueblos; y 3. la calidad del régimen contra el que se enfrentan, que, como ya se mencionó, puede ser colonial, racista o una ocupación ilegal o extranjera⁷².

Los MLN son, entonces, los representantes de los pueblos que luchan por su autodeterminación. No existe consenso para una definición de pueblos. Para Ruiloba, el término "pueblo" designa la misma realidad que el concepto de "nación"⁷³. Siguiendo lo postulado por este autor, para la determinación de un pueblo habrá que tener en cuenta, por un lado, elementos objetivos que pueden ser determinados por un territorio geográficamente diferenciado: unidad de raza, conciencia nacional, lengua, cultura, tradición y costumbres comunes y, por otro, un elemento subjetivo, que se explicita en la voluntad colectiva de constituir una nación independiente.

El principio de libre determinación de los pueblos se encuentra reconocido tanto en la Carta de las Naciones Unidas como en varias resoluciones que fueron adoptadas por la Asamblea General. La Resolución 1514/XV de la Asamblea General —titulada "Declaración sobre la Concesión de la Independencia y los Pueblos Coloniales"— reafirma el principio de libre determinación de los pueblos, prohíbe toda acción armada contra los pueblos en búsqueda de su independencia, ampara sus derechos y sostiene el respeto a los derechos soberanos de todos los pueblos. La Resolución 2220/XX de la Asamblea General, al admitir la legitimidad de todos los medios para obtener y respaldar el ejercicio de la autodeterminación, incluso el uso de la fuerza, también sirve para reafirmar la operatividad de este derecho. En esa misma línea pueden ser citadas las resoluciones 3070/XXVIII y 2825/XXV, también de la Asamblea General, o el artículo 1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos⁷⁴.

La Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos también establece:

1. Todos los pueblos tendrán derecho a la existencia. Tendrán el incuestionable e inalienable derecho a la autodeterminación. Decidirán libremente su status político y procurarán su desarrollo económico y social según la política que ellos mismos hayan escogido libremente.
2. Los pueblos colonizados u oprimidos tendrán derecho a liberarse de las ataduras de la dominación recurriendo a cualquier medio reconocido por la comunidad internacional.
3. Todos los pueblos tendrán derecho a la ayuda de los Estados firmantes de la presente Carta en su lucha por la liberación de la dominación extranjera, ya sea política, económica o cultural⁷⁵.

La primera mención por parte de las Naciones Unidas de los movimientos de liberación nacional se produce en 1965, mediante la Resolución 2105/XX de la Asamblea General, la cual "reconoce la legitimidad de la lucha que los pueblos bajo dominio colonial libran por el ejerci-

69 *Ibid.*

70 Vukas, Budislav, "States, peoples and minorities as subjects of international law", *R.C.A.D.I.*, vol. 281 (1991), p. 494.

71 *Ibid.*

72 Armas Pflüger, Frida; Barberis, Julio y Querol, María, *op. cit.*, p. 101.

73 Ruiloba Santana, Eloy, "Una nueva categoría en el panorama de la subjetividad internacional: el concepto de pueblo", en *Estudios de Derecho Internacional. Homenaje al profesor Mijail de la Muela*, Tecnos, Madrid, 1979, p. 303 y ss, citado en Pastor Ridruejo, José Antonio, *Curso de Derecho Internacional Público y Organizaciones Internacionales*, Tecnos, Madrid, 15.ª edic., 2011, p. 260.

74 Adoptado por la Asamblea General en su Resolución 2200 A (XXI), 16/12/1966; entró en vigor el 23/03/1978.

75 Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos, artículo 20.

cio de su derecho a la libre determinación y a la independencia, e invito a todos los Estados a prestar ayuda material y moral a los movimientos de liberación nacional de los territorios coloniales". En 1974, la Asamblea General reconoció expresamente los movimientos de liberación nacional de Angola, Mozambique, Palestina y Rhodesia.

Sin embargo, el ejercicio del derecho a la libre determinación no está exento de límites. El primer condicionante está impuesto por la integridad territorial de los Estados, principio que se encuentra reconocido en la Carta de las Naciones Unidas, y reforzado por la Resolución 2625/XXV antes mencionada⁷⁶, entre muchísimas otras resoluciones. En ese sentido, conviene resaltar que, ante una secesión o una guerra civil, quienes la lleven adelante no se encuentran amparados por el principio de libre determinación, y no constituirán movimientos de liberación nacional⁷⁷. Para verificar la aplicabilidad del derecho, entonces habrá que tener en cuenta los otros factores que mencionáramos.

Los MLN deben ser aceptados por sus respectivos pueblos como representantes e interlocutores válidos, y este reconocimiento debe ser también realizado por alguna organización regional o internacional. A excepción de los efectos generales de la teoría del reconocimiento en materia de Estados, que se verán en el capítulo 18, en el caso de los movimientos de liberación nacional tiene un efecto constitutivo⁷⁸. La regla general establece que el reconocimiento de estos movimientos se produce en dos tiempos diferentes: en primer lugar, la iniciativa es tomada por parte de una organización regional, para luego ser confirmada por la Asamblea General de las Naciones Unidas. Tal ha sido el caso de la OLP, de la SWAPO o de los movimientos de liberación nacional de las colonias portuguesas en África. Ante la ausencia de una organización internacional competente, este último rol puede ser jugado por el Movimiento de Países No-Alineados⁷⁹.

Los MLN tienen un vínculo directo con la soberanía, ya que procuran constituirse en nuevos Estados. Esto les otorga la característica de sujetos temporarios, ya que su propia finalidad así lo establece, puesto que, si son exitosos, se transformarán en un Estado independiente y, si no lo son, serán derrotados y oportunamente desaparecerán.

A diferencia de los grupos beligerantes, que serán tratados en el apartado siguiente, el reconocimiento de los MLN como sujetos del ordenamiento internacional no conlleva la necesidad de ejercer dominio territorial sobre una zona determinada. Es decir, el control efectivo de cierto territorio no es una característica distintiva de este tipo de sujetos. La historia ha demostrado que muchos de los movimientos reconocidos dentro de esta categoría llevaron a cabo sus fines desde países vecinos, desde donde conducían sus operaciones militares contra sus adversarios. Otro ejemplo es el caso de la Organización para la Liberación de Palestina, cuyo reconocimiento como MLN fue anterior al ejercicio de cualquier tipo de jurisdicción exclusiva sobre ningún territorio⁸⁰.

Los MLN interactúan en diversos aspectos de la vida internacional. Son titulares de varios derechos y obligaciones, especialmente referidos al objetivo que persiguen. Así, deben respetar las normas que les impone el derecho internacional general, y particularmente las que regulan los conflictos armados. Los MLN pueden ejercer también el *jus tractum* y el *jus legationis*. En ese sentido, pueden celebrar tratados con otros sujetos del ordenamiento jurídico internacional —como ejemplo podemos mencionar los tratados que dan por finalizada la guerra de liberación y la obtención de la independencia— como así también con Estados vecinos que fijen los límites de los respectivos territorios, entre otros ejemplos.

En el marco de la ONU, los movimientos de liberación nacional, una vez cumplidos los recaudos que se mencionaron, son invitados a título de "observadores", sobre la base de una práctica común y constante que se desarrolló a partir de 1960. Entre las facultades que se

les otorgan podemos mencionar la participación de los representantes de los MLN en las Sesiones Ordinarias de la Asamblea General y en el Consejo de Seguridad, como así también en los trabajos pertinentes de las comisiones principales de la Asamblea General y de otros órganos subsidiarios interesados, y en conferencias, seminarios, y otras reuniones celebradas con los auspicios de las Naciones Unidas que sean de interés para sus países⁸¹. Sin perjuicio de la generalidad precedentemente efectuada, las facultades que se les asignen dependerán de cada movimiento en particular y de su estructura y reconocimiento por parte la comunidad internacional. Por ejemplo, la OLP y la SWAPO han sido admitidas como miembros plenos en muchas otras organizaciones internacionales. Es dable destacar que a la Organización para la Liberación de Palestina le fue conferido el estatus de observador mediante la Resolución 3237/XXIX de la Asamblea General⁸².

En cuanto al derecho de legación, los MLN pueden tener representación en distintos Estados con los que mantienen relaciones internacionales. Barberis señala que el tipo de representación dependerá del reconocimiento del estatus del movimiento por parte del Estado receptor. Así, la OLP ha tenido representaciones diplomáticas similares a las de las embajadas en la República Democrática de Alemania, en Senegal, etc.⁸³

Por otro lado, el Protocolo I a las Convenciones de Ginebra de 1949 (1977) sobre derecho internacional humanitario prevé en su artículo 98 la aceptación del Protocolo y de las Convenciones de Ginebra por parte de los MLN, por medio de una declaración del representante del movimiento dirigida al país depositario. En igual sentido, el Convenio sobre Ciertas Armas Convencionales (1981) identifica a los MLN como destinatarios de derechos y obligaciones internacionales.

Obviamente, el ejercicio de estos derechos y el cumplimiento de las obligaciones internacionales les exigen la existencia de una cierta estructura político-administrativa y un ordenamiento jurídico propio (como la Carta Orgánica de la OLP y las Constituciones de distintos movimientos de liberación nacional africanos⁸⁴), como así también suficientes recursos materiales y humanos.

La personalidad jurídica internacional de los MLN, como la de los pueblos, es por definición temporal y funcional. Su razón de existir concluye cuando termina la guerra de liberación y se produce la independencia del Estado. En ese sentido, el nuevo Estado aparece como su sucesor⁸⁵.

3.3. Los grupos beligerantes

En el derecho internacional tradicional se incluye a los grupos beligerantes entre los sujetos del derecho internacional. No obstante, en la actualidad se trata de una categoría meramente teórica, ante la dificultad de individualizar —en la práctica— a grupos que cumplan con los requisitos para encuadrar en ella, a fin de que se les reconozca subjetividad internacional. De hecho, muchos manuales de derecho internacional ya ni siquiera mencionan esta categoría entre los sujetos del derecho internacional.

Un grupo beligerante es aquel grupo armado, organizado militarmente, que se halla bajo las órdenes de un comando responsable, se encuentra en lucha armada con un Estado y controla parte del territorio de este. Si dicho grupo es reconocido como beligerante por el Estado en cuestión y/o por terceros Estados, gozará de personalidad internacional, derivando de ello una serie de consecuencias.

76 Adoptada el 24/10/1970.

77 Armas Pfrter, Frida; Barberis, Julio y Querol, María, *op. cit.*, pp. 108-104.

78 Nguyen Quoc Dinh; Dallier, Patrick; Forteau, Mathias y Pollet, Alain, *Droit International Public*, LGDL, París, 8.ª edic., 2009, pp. 582-583; en sentido contrario, Armas Pfrter, Frida; Barberis, Julio y Querol, María, *op. cit.*, p. 109.

79 Nguyen Quoc Dinh; Dallier, Patrick; Forteau, Mathias y Pollet, Alain, *op. cit.*, p. 583.

80 Armas Pfrter, Frida; Barberis, Julio y Querol, María, *op. cit.*, p. 109.

81 Ver, entre otras, las Resoluciones 3236 (XXIX) y la 3412 (XXX) de la Asamblea General.

82 Resolución 3287 (XXIX), "Condición de observadora de la Organización de Liberación de Palestina", adoptada el 22/11/1974.

83 Barberis, *op. cit.*, pp. 268-267.

84 Armas Pfrter, Frida; Barberis, Julio y Querol, María, *op. cit.*, p. 108.

85 Nguyen Quoc Dinh; Dallier, Patrick; Forteau, Mathias y Pollet, Alain, *op. cit.*, p. 583. Estos autores sostienen que, a medida que los distintos MLN vayan alcanzando su objetivo, el estudio del régimen jurídico de estos consistirá en una "curiosidad jurídica".

En sentido estricto, el grupo insurgente es aquel que no alcanza a reunir los elementos exigidos para ser beligerante. Aunque en ocasiones se hable indistintamente de grupo beligerante, insurgente o insurreccional.

En cuanto a las consecuencias del reconocimiento de un grupo beligerante, podemos señalar las siguientes. En primer lugar, el Estado que mantiene la lucha con el grupo beligerante no será responsable por los actos ilícitos cometidos por dicho grupo que causen daño a terceros o a la población, el cual tendrá responsabilidad propia⁸⁶. La Comisión de Derecho Internacional se refiere con una expresión más amplia a los "movimientos insurreccionales", a fin de explicar en qué únicos supuestos su conducta le es atribuible a un Estado⁸⁷. En segundo lugar, a la lucha armada que mantenga el grupo con las fuerzas armadas del Estado se aplicarán las reglas del derecho internacional humanitario que rigen en los conflictos armados internos —a diferencia del resto de las situaciones de violencia que se generen dentro del territorio del Estado, las cuales estarán sujetas a su legislación interna, por ejemplo, encuadrando sus acciones en delitos penales comunes—. Como se verá en el capítulo 46, el Protocolo Adicional II a los Convenios de Ginebra de 1949 se aplica a los conflictos armados sin carácter internacional "que se desarrollen en el territorio de una Alta Parte Contratante entre sus fuerzas armadas y fuerzas armadas disidentes o grupos armados organizados que, bajo la dirección de un mando responsable, ejerzan sobre una parte de dicho territorio un control tal que les permita realizar operaciones militares sostenidas y concertadas y aplicar el presente Protocolo"⁸⁸.

Los terceros Estados que reconozcan al grupo beligerante deberán mantener una posición de neutralidad respecto del conflicto que dicho grupo sostiene con el Estado cuya parte del territorio controla, no pudiendo asistir con armas o prestar asistencia militar ni a una parte ni a la otra⁸⁹.

El reconocimiento de beligerancia es un acto discrecional por parte de los Estados y se basa en la existencia de una situación de hecho⁹⁰. Si bien el Estado que reconoce a un grupo beligerante en su territorio se desliga de responsabilidad internacional por lo daños que dicho grupo pueda causar a terceros, la decisión que tome puede tener un costo político importante, ya que implica reconocer la pérdida de control sobre una parte de su territorio. Además, a partir del reconocimiento, el grupo se coloca en la misma posición que el Estado en lo que concierne al derecho internacional humanitario aplicable. Por ello, Paolillo opina que "los más interesados en que se proceda al reconocimiento de beligerancia son los propios revolucionarios. No sólo dicho reconocimiento les confiere un estatuto internacional que les acarrea indudables beneficios políticos, sino que les coloca ante la comunidad internacional en igualdad de condiciones con el Gobierno, en virtud del deber de neutralidad que deben observar los terceros Estados"⁹¹.

3.4. Los individuos

A partir de la adopción de tratados y otros instrumentos internacionales que consagran derechos humanos a las personas, consideramos que ya no quedan dudas acerca de que los individuos —o "las personas humanas", como refieren algunos internacionalistas— son sujetos de derecho internacional.

⁸⁶ Paolillo, Felipe, "Los sujetos del derecho Internacional", en *Derecho Internacional Público*, Jiménez de Aréchaga (dir.), Fundación de Cultura Universitaria, Montevideo, t. II, 1.ª edic., 1995, p. 28.

⁸⁷ Comentarios de la CDI al Proyecto de artículos sobre responsabilidad del Estado por hechos internacionalmente ilícitos, aprobado por la CDI en su quincuagésimo tercer período de sesiones, Ginebra, 2001 (disponible en <http://www.un.org/law/ilc>), comentario al art. 10, párr. 9. Allí se explica que "Una definición general de los tipos de grupos que abarca la expresión 'movimiento insurreccional', tal como se emplea en el artículo 10, resulta difícil en vista de la gran variedad de formas que pueden tomar en la práctica los movimientos insurreccionales". Asimismo, se afirma que la definición de "fuerzas armadas disidentes" contenida en el art. 1 del Protocolo Adicional II "refleja, en el contexto de los Protocolos, la idea fundamental de un 'movimiento insurreccional'".

⁸⁸ Protocolo Adicional a los Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949 relativo a la protección de las víctimas de los conflictos armados sin carácter internacional, suscrito el 08/08/1977, art. 1(1).

⁸⁹ Ver Paolillo, Felipe, *op. cit.*, pp. 27-28.

⁹⁰ *Ibid.*, p. 28.

⁹¹ *Ibid.*

En efecto, la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre (1948), la Declaración Universal de Derechos Humanos (1948) y los Pactos de las Naciones Unidas de 1966, entre otros tratados y declaraciones, tanto a nivel universal como regional, otorgan derechos humanos directamente a los individuos. Por ejemplo, toda persona tiene derecho a la vida, a la libertad, a la seguridad, a la libertad de expresión, a no ser torturada, a trabajar, a formar una familia, etc.

Asimismo, se ha reconocido a los individuos legitimación para presentar reclamos ante órganos internacionales en contra de un Estado, por violación de los derechos humanos. En el sistema universal, en virtud de lo establecido por diversos tratados de derechos humanos, los individuos pueden presentar peticiones ante órganos de vigilancia de los tratados, como el Comité de Derechos Humanos, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales⁹², el Comité contra la Tortura, entre otros. En el sistema interamericano, las personas (y los grupos de personas) pueden acudir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a través de una petición, contra un Estado americano que ha violado los derechos humanos contenidos en la antes mencionada Declaración Americana o, en caso de que el Estado sea parte, en la Convención Americana sobre Derechos Humanos (1969)⁹³. En el sistema europeo, *a fortiori*, desde 1998 —cuando entró en vigor la enmienda prevista en el Protocolo 11⁹⁴— los individuos tienen el derecho de presentar una demanda directamente ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, por violación de uno de los derechos contenidos en la Convención Europea de Derechos Humanos (1950)⁹⁵.

Así como gozan de derechos humanos, los individuos también tienen algunas obligaciones internacionales, que les han impuesto los Estados a través de tratados internacionales. En efecto, los individuos están obligados a no cometer crímenes internacionales (genocidio, crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad, etc.), puesto que, en caso de hacerlo, surge su responsabilidad penal internacional, como se desarrolla en el capítulo 47 de esta obra.

No obstante, en el ámbito internacional el individuo posee una personalidad internacional muy limitada en comparación con otros sujetos. Cabe destacar que, si bien pueden celebrar contratos internacionales, no tienen capacidad para celebrar tratados internacionales en su propio nombre (obviamente, pueden actuar a nombre de un Estado).

3.5. Los inversores extranjeros

Los inversores extranjeros son personas físicas o jurídicas que han realizado una inversión de cierta envergadura en Estados extranjeros, es decir, de los cuales no son nacionales.

Algunos autores, en lugar de discutir acerca de la personalidad internacional de los inversores extranjeros, se refieren puntualmente a las empresas multinacionales⁹⁶ o corporaciones para aludir a su personalidad internacional en el contexto del derecho de las inversiones. Sin embargo, en dicha rama del derecho, los derechos sustanciales o procedimentales de los que puedan gozar las empresas multinacionales son —con algunas salvedades— similares a los que pueden tener las personas físicas que califiquen de inversores extranjeros. Por tal motivo, creemos que es preferible hablar directamente de la subjetividad internacional de los inversores extranjeros, a fin de incluir tanto a las personas físicas como a las jurídicas —entre ellas, las corporaciones o empresas multinacionales—.

Existen más de tres mil tratados internacionales —la mayoría de ellos bilaterales— que regulan el tratamiento que los Estados contratantes deben darle a los inversores extranjeros y a sus inversiones. Básicamente, dichos tratados establecen una serie de estándares de pro-

⁹² Ver González Napolitano, Silvina, "La protección de los derechos humanos a través de los Pactos de 1966", en *Introducción al Estudio de los Derechos Humanos*, González Napolitano, Silvina y Pulvirenti, Orlando (coords.), Errepar, Buenos Aires, 2011, pp. 99-119.

⁹³ Para mayor detalle ver Gómez Fernández, Lucía, "La Comisión Interamericana de Derechos Humanos", en *Introducción al Estudio de los Derechos Humanos*, *op. cit.*, pp. 127-170.

⁹⁴ Abierto a la firma el 11/05/1994 y en vigor desde el 01/11/1998.

⁹⁵ Ver Lavin, Renzo, "La protección de los derechos humanos en Europa", en *Introducción al Estudio de los Derechos Humanos*, *op. cit.*, pp. 247-272.

⁹⁶ Walter, Christian, *op. cit.*, párrs. 19-20.

tección (no expropiación sin causa justa y pronta indemnización; trato justo y equitativo; no adopción de medidas arbitrarias o discriminatorias; plena protección y seguridad; igual trato que a los nacionales o nacionales de terceros Estados; libre transferencia de ganancias; etc.)⁹⁷ que deberán respetar los Estados contratantes en los cuales se realiza la inversión. Asimismo, la mayoría de los tratados de inversión prevé un mecanismo de solución de controversias entre inversores y Estados, en cuyo marco los inversores extranjeros pueden optar por someter ellos mismos la controversia al arbitraje internacional contra el Estado extranjero⁹⁸. A nivel local, los Estados también han establecido normas para la protección de las inversiones extranjeras en sus legislaciones internas y en algunos acuerdos de inversión celebrados con inversores extranjeros, en los cuales también se puede pactar el sometimiento de una disputa al arbitraje internacional.

Por otra parte, existen también iniciativas para imponer obligaciones a las corporaciones o empresas multinacionales⁹⁹, como se desarrolla en el capítulo 17.

Para determinar si los inversores extranjeros son sujetos de derecho internacional es necesario verificar si los mencionados tratados internacionales (o las normas consuetudinarias) les otorgan algún derecho o le imponen alguna obligación en el plano internacional.

La discusión doctrinaria se centra en si las disposiciones de los tratados de protección de las inversiones extranjeras contienen tan solo obligaciones para los Estados o también derechos para los inversores. Por ejemplo, es común que un tratado bilateral de inversión estipule que "las inversiones no serán objeto de un trato discriminatorio" o que "los Estados contratantes otorgarán a las inversiones un trato justo y equitativo", en lugar de disponer que "los inversores tienen derecho a no ser objeto de un trato discriminatorio y a gozar de un trato justo y equitativo". La cuestión es, entonces, si el inversor extranjero tiene derecho internacional a ser tratado de determinada manera, o si el derecho pertenece al Estado de su nacionalidad, de modo que es el Estado el que tiene el derecho a que su nacional que califique de inversor extranjero sea tratado de determinada manera por los Estados en los cuales realice su inversión. Básicamente existen dos posturas, una a favor y otra en contra de la subjetividad internacional de los inversores extranjeros. Comenzaremos por esta última.

a) En contra de la subjetividad internacional de los inversores extranjeros (teoría de la derivación o subrogación)

Los partidarios de esta posición entienden que, por la forma en que fueron redactados, los tratados de protección de las inversiones extranjeras solo contienen obligaciones interestatales, ya que, a diferencia de los tratados sobre derechos humanos, los tratados de inversión no estipulan, por ejemplo, que "el inversor tiene derecho a ...", sino que "el Estado tiene la obligación de ...". Los inversores extranjeros son los beneficiarios de los tratados y en la mayoría de los casos tienen legitimación procesal para acceder al arbitraje internacional (se trataría, según esta postura, de una delegación del derecho del Estado al ejercicio de la protección diplomática de sus inversores; de modo que, cuando los inversores reclaman, lo hacen poniéndose en el lugar del Estado¹⁰⁰), pero no poseen derechos sustanciales.

En apoyo de este argumento se cita el caso *Loewen c. Estados Unidos*, en el que el tribunal arbitral afirmó que "No hay justificación para trasplantar las normas derivadas del derecho privado a un ámbito correspondiente al derecho internacional en el que por razones de conveniencia se permite a las demandantes hacer valer lo que originalmente son los derechos de los Estados parte"¹⁰¹.

97 El contenido de estos tratados se analiza *in extenso* en el capítulo 44 de esta obra.

98 Ver capítulo capítulo 45 de esta obra.

99 Por ejemplo, el Modelo de acuerdo internacional para el desarrollo sustentable del Instituto Internacional para el desarrollo sustentable (Model International Agreement on Investment for Sustainable Development) de abril de 2006.

100 Douglas, Zachary, *The International Law of Investment Claims*, Cambridge University Press, Cambridge, 2008, p. 11.

101 *Loewen Group, Inc. y Raymond L. Loewen c. Estados Unidos de América* (caso CIADI N° ARB(AF)/98/3), Laudo, 26/06/2003, parág. 283 (traducción libre).

Este tema también se discutió en el caso *Archer c. México*, en oportunidad en que el tribunal arbitral se preguntó si el impuesto establecido por el Estado demandado había afectado derechos individuales sustantivos de las demandantes. Según el tribunal, "La cuestión plantea el problema de si en el Capítulo XI del TLCAN [Tratado de Libre Comercio de América del Norte] se establece un régimen autónomo de derechos sustantivos y procesales para inversionistas conforme al TLCAN, y si estos derechos son independientes de la relación obligatoria entre los Estados Miembros"¹⁰². La parte demandante sostenía que los inversores tenían derechos independientes y directos, los cuales existían al margen de la relación obligatoria entre los Estados miembros¹⁰³. México, en cambio, arguyó que había que hacer una distinción entre procedimiento y sustancia; las obligaciones sustantivas eran obligaciones interestatales, sin perjuicio de que se hubiera otorgado un derecho de acción a los inversionistas¹⁰⁴. Al respecto, el tribunal arbitral consideró que la posición correcta era la del Estado demandado, puesto que se ajustaba a la estructura tradicional del derecho internacional. En efecto, el capítulo XI del TLCAN establecía "obligaciones sustantivas de aplicación entre los Estados, sin establecer derechos individuales para las Demandantes", de modo que "Si se produce un incumplimiento de cualquiera de estas obligaciones, el inversor puede entablar una acción contra el Estado receptor ante un tribunal arbitral internacional a fin de solicitar el pago de una compensación, aunque en realidad el inversor estará subrogándose y haciendo valer los derechos de su Estado de origen". Si bien el tribunal está de acuerdo en que el derecho internacional en determinadas circunstancias puede conceder derechos directos al individuo, considera que no es el caso del capítulo XI del TLCAN, el cual se diferencia de los tratados de derechos humanos. Aquí "El inversor acepta la oferta del Estado receptor de someter la disputa a arbitraje una vez presentada la solicitud de arbitraje, pudiendo en este momento el inversor renunciar a sus derechos procesales. La naturaleza de las obligaciones sustantivas que se recogen en la Sección A no permite renuncia alguna por parte del inversor, ya que se trata de [obligaciones] que permanecen en vigor a [nivel] interestatal y no pueden, por lo tanto, ser objeto de renuncia [...]"¹⁰⁵.

b) A favor de la subjetividad internacional de los inversores extranjeros (teoría directa)

La posición de quienes se enrolan en esta postura ha sido sintetizada por el tribunal arbitral del caso *Archer c. México* de la siguiente manera:

El resultado de la teoría directa, respaldada por las Demandantes, consiste en que un tratado de protección de inversiones establece dos relaciones jurídicas distintas: una entre el inversor y el Estado receptor; y otra entre los Estados parte. Por lo tanto, pueden surgir dos tipos de controversias en la aplicación de un tratado de protección de inversiones: entre las Partes contratantes –acerca de la interpretación y aplicación del tratado– o entre el Estado receptor y el inversor. Los tratados de protección de inversiones contienen disposiciones independientes que regulan estos dos tipos de controversias¹⁰⁶.

En virtud de esta teoría, los inversores tienen derechos directos otorgados por los tratados de inversión¹⁰⁷. Así, en el caso *Marvin Roy Feldman Karpa c. México*, el tribunal arbitral sostuvo que México había violado los derechos del demandante establecidos en el capítulo XI del

102 *Archer Daniels Midland Company y Tate & Lyle Ingredientes Americas, Inc. c. Estados Unidos Mexicanos* (caso CIADI N° ARB(AF)/04/06), Laudo, 21/11/2007, parág. 161.

103 *Ibid.*, parág. 182.

104 *Ibid.*, parág. 184.

105 *Ibid.*, párrs. 168-174.

106 *Ibid.*, parág. 168.

107 Ver Douglas, Zachary, *op. cit.*, p. 32 (nota al pie 160), que cita a Burdoau, Geneviève, "Nouvelles perspectives pour l'arbitrage dans le contentieux économique intéressant l'Etat", *Revue de l'arbitrage*, vol. 3 (1995), p. 12 y ss.; Paulsson, Jan, "Arbitration Without Privilege", *ICSID Review - Foreign Investment Law Journal*, vol. 10 (1995), p. 256; Waldo, Thomas, "Investment Arbitration under the Energy Charter Treaty", *Arbitration International*, vol. 12, n.º 4 (1996), pp. 435-487.

TLCAN. En particular, siguiendo una postura distinta a la que adoptó más tarde el tribunal del caso *Archer c. México*, afirmó que "El esquema del Capítulo XI establece el derecho al trato nacional para los inversionistas (y a una indemnización por daños en caso de violación de tal derecho) que se diferencia del derecho a una indemnización por daños por actos de expropiación" y que, en conclusión, "México ha violado los derechos del Demandante a no ser discriminado, conforme al Artículo 1102 del TLCAN"¹⁰⁸.

En el caso *A.M.T. c. Zaire* el inversor fue descripto como un beneficiario de derechos sustantivos del tratado bilateral de inversión¹⁰⁹.

Por su parte, Zachary Douglas considera que, en virtud del régimen establecido en los tratados de inversión, el inversor somete una acción basada en la reivindicación de un derecho propio, más que un derecho del Estado de su nacionalidad, y advierte que esta fue la posición del Relator Especial Dugard de la Comisión de Derecho Internacional al tratar el proyecto sobre protección diplomática, siendo el régimen especial de las inversiones distinto del régimen de la protección diplomática¹¹⁰. Douglas también menciona que algunos modelos de tratados bilaterales de inversión están redactados de manera tal que reconocen también a los inversores derechos sustantivos¹¹¹.

En conclusión, más allá de cómo se encuentren redactados los tratados bilaterales de inversión respecto de las obligaciones sustantivas, y de la discusión teórica que se plantea en la doctrina y la jurisprudencia, lo cierto es que un buen número de inversores extranjeros goza del derecho procesal de accionar en el plano internacional por su propia cuenta, lo que convierte a cada uno de ellos en un "centro de imputación de normas internacionales". La definición de sujeto de derecho internacional generalmente aceptada no distingue entre distintas categorías de derechos internacionales (procesales/sustanciales) que puedan adquirir los entes que califiquen de tales.

Sin embargo, cabe destacar que los inversores extranjeros poseen una personalidad internacional muy limitada en comparación con otros sujetos. Además del derecho de acceder al arbitraje internacional –según está previsto en la mayoría de los tratados de inversión–, al igual que cualquier individuo que no califique como inversor, los inversores extranjeros (sean o no empresas multinacionales) pueden celebrar contratos internacionales –o internacionalizados– (independientemente de cuál sea su denominación), pero no tienen capacidad para celebrar tratados internacionales, cuestión que en su momento ha sido objeto de debate entre los académicos. Tales contratos están regulados por el derecho interno de algún Estado, pero no por el derecho internacional –sin perjuicio de que posean algún elemento que los internacionalice, como, por ejemplo, una cláusula que les permita acceder al arbitraje internacional–, como se verá en el capítulo 6 de esta obra.

3.6. Las organizaciones no gubernamentales

Las organizaciones no gubernamentales (ONG) son entidades sin fines de lucro creadas por individuos bajo la legislación interna de algún Estado, con el fin de velar por ciertos intereses colectivos. Algunas de ellas actúan también fuera de la frontera del Estado donde fueron creadas, como, por ejemplo: Médicos sin Frontera, Greenpeace, Amnistía Internacional.

En el plano internacional estas organizaciones han obtenido numerosos logros. Por ejemplo, en la actualidad, algunas de ellas:

- participan como observadores en conferencias internacionales y en reuniones de órganos internacionales (aunque generalmente sin voz ni voto);
- llaman la atención de los Estados y de las organizaciones internacionales gubernamentales respecto de problemas internacionales;

108 *Marvin Roy Feldman Karpa c. Estados Unidos Mexicanos* (caso CIADI N° ARB(AF)/99/01), Laudo Final, 16/12/2002, párrs. 137 y 137.

109 *American Manufacturing & Trading, Inc. c. República de Zaire* (caso CIADI N° ARB/93/1), Laudo, 21/02/1997, párr. 6.06.

110 Douglas, Zachary, op. cit., pp. 32-35.

111 *Ibid.*, p. 35, que cita al modelo de tratado bilateral de inversión de Austria (art. 5, inc. 3).

- presentan peticiones por violación de derechos humanos y brindan asesoramiento y asistencia jurídica a las víctimas;
- poseen estatus de entidades consultivas de la Organización de las Naciones Unidas, y son consultadas periódicamente en el marco del Consejo Económico y Social (ECOSOC).

Pese a que poseen capacidad procesal para presentar denuncias por violación de los derechos humanos ante órganos internacionales, en general no son consideradas sujetos del derecho internacional, sino actores internacionales, puesto que actúan para hacer efectivos derechos de terceros (seres humanos víctimas de violaciones de derechos humanos), no propios. Sin embargo, tal como mencionamos al comienzo de este capítulo, la comunidad internacional se encuentra en constante desarrollo y evolución, y también lo está el ordenamiento jurídico que la regula.

Al respecto, resulta útil señalar el trabajo realizado por la Comisión de Derecho Internacional en su proyecto sobre la responsabilidad de las organizaciones internacionales. En su primer informe, el relator especial Giorgio Gaja, al referirse a la cuestión de la definición de "organización internacional", precisó que "debe partirse de la premisa de que la responsabilidad en derecho internacional sólo puede imputarse a un sujeto de derecho internacional"; en consecuencia, "Las normas del derecho internacional no pueden imponer a una entidad obligaciones 'primarias' y obligaciones 'secundarias' para el caso de que se incumpla una de las obligaciones 'primarias' a menos que tal entidad tenga personalidad jurídica en derecho internacional. A la inversa, una entidad debe considerarse sujeto de derecho internacional incluso si tiene una sola obligación en virtud del derecho internacional. Así, si existe tal obligación en derecho internacional para una organización, puede suscitarse la cuestión de su responsabilidad. Lógicamente, un estudio sobre la responsabilidad de las organizaciones internacionales debería comprender todas las organizaciones que sean sujeto de derecho internacional"¹¹².

El relator especial también destacó que la cuestión de la personalidad jurídica de las organizaciones internacionales ha sufrido una considerable evolución desde que en 1949 la Corte Internacional de Justicia reconociera expresamente la subjetividad internacional de la Organización de las Naciones Unidas. En ese mismo sentido, Gaja se refirió al reconocimiento por la CIJ de la personalidad jurídica internacional de los individuos:

La Corte declaró en el caso *La Grand* que los individuos también son sujetos de derecho internacional y esta postura podría incluso llevar a la Corte a reconocer la personalidad jurídica de organizaciones no gubernamentales. Sería difícil entender por qué los individuos pueden adquirir derechos e incurrir en obligaciones en virtud del derecho internacional mientras que esta posibilidad no existiría para las organizaciones internacionales suponiendo siempre que se trate de entidades distintas de los miembros que las componen¹¹³.

Sin perjuicio de que el proyecto de la CDI en cuestión dejó de lado el estudio de la responsabilidad internacional de las ONG a raíz de cuestionamientos levantados por diversos Estados, la puerta parece haber quedado abierta para considerar a estas entidades como nuevos sujetos del derecho internacional. Analicemos un poco más en profundidad sus características particulares y su naturaleza jurídica.

Como mencionamos, las ONG gozan de personalidad jurídica en los ordenamientos internos de los Estados en los cuales han sido registradas, pero como muchas de ellas se desempeñan en territorios de más de un Estado, han existido varios intentos para que estas sean reguladas por el derecho internacional. Por ejemplo, en 1910 tanto el Instituto de Derecho Internacional como la Asociación de Derecho Internacional promovieron la suscripción de un tratado multilateral que regulara la personalidad jurídica internacional de las ONG que tuvie-

112 Primer Informe sobre la Responsabilidad de las Organizaciones Internacionales, Doc. A/CN.4/532, 26/3/2003, párr. 15 (énfasis agregado).

113 *Ibid.*, párr. 17 (citas omitidas; énfasis agregado).

ran funciones en más de un Estado¹¹⁴, aunque los intentos para la celebración de tal acuerdo fueron infructíferos.

A nivel universal, un tratado de estas características aún no ha podido celebrarse principalmente debido a la reticencia de los Estados de reconocer la participación esencial de estas organizaciones en el ordenamiento jurídico internacional; sin embargo, una organización regional, el Consejo de Europa, ha adoptado el 27 de abril de 1986¹¹⁵ la Convención Europea sobre el Reconocimiento de la Personalidad Jurídica de las Organizaciones Internacionales No Gubernamentales¹¹⁶—también conocida como “la Convención 124”—. El artículo 1—que regula el ámbito de aplicación de esta Convención—estipula que las ONG incluidas son las “asociaciones, fundaciones u otras instituciones privadas que reúnan las condiciones siguientes: tener un fin no lucrativo de utilidad internacional; haber sido creadas por un acto del derecho interno de una Parte, ejercer una actividad efectiva en, por lo menos, dos Estados; tener una sede estatutaria en el territorio de una parte y la sede real en el territorio de esa Parte o de otra Parte”. La Convención prevé en su artículo 2 que una ONG que cumpla con los requisitos mencionados gozará de personalidad jurídica en todos los Estados parte de la Convención¹¹⁷. Es decir, nos encontramos frente a una norma internacional—aunque de alcance regional—que otorga derechos directamente a las ONG.

Parece imposible no referirse al artículo 71 de la Carta de las Naciones Unidas, ya que se trata del primer artículo de un tratado multilateral que refiere a las ONG. Este establece: “El Consejo Económico y Social podrá hacer arreglos adecuados para celebrar consultas con organizaciones no gubernamentales que se ocupen en asuntos de la competencia del Consejo. Podrán hacerse dichos arreglos con organizaciones internacionales y, si a ello hubiere lugar, con organizaciones nacionales, previa consulta con el respectivo Miembro de las Naciones Unidas”. Este estatus es conocido en la doctrina como “estatus consultivo” y se encuentra regulado actualmente por la Resolución 1996/31 del ECOSOC que establece el procedimiento para que las ONG adquieran este reconocimiento en el marco de las Naciones Unidas. Si bien el artículo 71 refiere únicamente al funcionamiento del ECOSOC, la práctica en relación con las ONG que ha tenido este órgano puede extenderse a todo el sistema de la ONU¹¹⁸.

En cuanto a la participación ante jurisdicciones internacionales, la principal función que han cumplido las ONG es la de presentar *amicus curiae* antes distintos tribunales internacionales. Un buen número de ONG ha realizado este tipo de presentaciones, por ejemplo, ante el Tribunal Penal Internacional para la Ex Yugoslavia y el Tribunal Penal Internacional para Ruanda¹¹⁹. Sin embargo, en los últimos años se ha abierto la posibilidad de que sean las mismas ONG las que puedan iniciar los procedimientos ante los tribunales internacionales y órganos cuasi-jurisdiccionales. Por ejemplo, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos se encuentra habilitado por el Convenio Europeo de Derechos Humanos para recibir denuncias de ONG por violaciones a los derechos humanos reconocidos en dicho Convenio¹²⁰. En ese mismo sentido, la Convención Americana sobre Derechos Humanos prevé en su artículo 44: “Cualquier persona o grupo de personas, o entidad no gubernamental legalmente reconocida en uno o más Estados miembros de la Organización, puede presentar a la Comisión peticiones que contengan denuncias o quejas de violación de esta Convención por un Estado parte”. Asimismo, la Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos recibe denuncias no solo de los Estados y los individuos, sino también de las ONG, por supuestas violaciones a la Carta Africana¹²¹. En efecto, en la primera decisión de fondo que pronunció la Corte Africana de Derechos Humanos

114 Charnovitz, Steve, “Nongovernmental Organizations and International Law”, *A.J.I.L.*, vol. 100 (2006), p. 356.

115 En vigor desde el 01/01/1991.

116 Disponible en <http://conventions.coe.int/Treaty/Commun/QueVoulezVous.asp?NT=124&CM=8&CL=ENG>.

117 Martens, Kerstin, “Examining the (Non-)Status of NGOs in International Law”, *Indiana Global Legal Studies Journal*, vol. 1 (2003), p. 22.

118 *Ibid.*, p. 17.

119 Charnovitz, Steve, *op. cit.*, p. 353.

120 Artículo 34 de la Convención Europea de Derechos Humanos modificada por el Protocolo n.º 11 (abierto a la firma el 11/05/1994 y en vigor desde el 01/11/1998).

121 Motela, Ahmed, “Non-Governmental Organisations in the African System”, en *The African Charter on Human and Peoples' Rights. The System on Practice, 1986-2000*, Evans, Malcom y Murray, Rachel (eds.), Cambridge University Press, Cambridge, 2002, p. 247.

y de los Pueblos, en el asunto *Tanganyika Law Society et al. c. Tanzania*, expresamente se refirió a la posibilidad de que las ONG sean parte en los procesos contenciosos que sean sometidos a la jurisdicción internacional de la Corte¹²².

En materia de arbitrajes, no podemos dejar de mencionar el caso del buque *Rainbow Warrior*, perteneciente a Greenpeace, que en 1985 fue bombardeado cuando se encontraba en aguas de Nueva Zelanda realizando una campaña con el fin de protestar por los ensayos nucleares de Francia en el Pacífico. El ataque produjo la muerte de una persona y el hundimiento del buque; los responsables de ello fueron dos agentes del servicio francés. Además de un arbitraje interestatal entre Nueva Zelanda y Francia¹²³, el Gobierno francés acordó someterse a un procedimiento arbitral bajo el derecho británico con el *Stichting Greenpeace Council*, en nombre de todas las organizaciones de Greenpeace, respecto de la compensación debida a la ONG¹²⁴. Malanczuk considera que este es el primer caso internacional en la historia de un acuerdo entre un Estado soberano y una ONG para someter una disputa a arbitraje¹²⁵. El Tribunal Arbitral laudó condenando a Francia al pago de USD 8.159.000 a la ONG Greenpeace por los daños derivados de la operación que hundió el buque en cuestión¹²⁶.

La influencia de las ONG en distintos regímenes especializados del derecho internacional ha sido primordial, en particular en el derecho internacional de los derechos humanos, el derecho internacional penal, el derecho internacional humanitario y el derecho internacional ambiental¹²⁷. La participación de las ONG ha sido decisiva, para mencionar un ejemplo, en la Conferencia de Roma para la creación de una Corte Penal Internacional. Al menos 236 ONG fueron acreditadas en dicha conferencia, incluso superando la cantidad de las representaciones correspondientes a los Estados que integran la comunidad internacional¹²⁸. Su influencia no solo se limitó a proponer la redacción del Estatuto de Roma, sino que también jugó un rol preponderante en el proceso de ratificación de dicho tratado por parte de los Estados, mediante campañas (*lobby*) en ellos. Incluso algunas de las ONG participantes representaban a diversos pequeños Estados que, por razones económicas, no estaban presentes en la Conferencia de Roma¹²⁹.

A partir de lo observado, podemos afirmar que el derecho internacional les reconoce hoy en día a las organizaciones no gubernamentales una personalidad jurídica limitada, tal como acontece con el supuesto de los individuos.

3.7. Sujetos atípicos o sui generis

3.7.1. La Iglesia Católica/Santa Sede y la Ciudad del Vaticano

Como punto de partida, debemos aclarar que los autores no coinciden en la identificación de este sujeto del derecho internacional. Así, la mayoría se refiere a la “Santa Sede”, mientras otros hablan del “Vaticano”, la “Ciudad del Vaticano” o la “Iglesia Católica”. Incluso algunos Estados han reconocido a la vez la personalidad jurídica internacional de la Santa Sede y de la

122 *Tanganyika Law Society et al. c. La República de Tanzania*, Corte Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos, Fallo, 14/09/2018 (“La Corte Africana tiene jurisdicción para escuchar todos los casos y disputas que le sean sometidos concernientes a la interpretación y aplicación de la Carta, presentados por individuos u organizaciones no gubernamentales (ONGs) si el Estado contra el cual el caso es entablado ha autorizado tales acciones”).

123 *Asunto del Rainbow Warrior*, sentencia arbitral, 30/04/1990, *R.I.A.A.*, vol. xx, p. 217.

124 Hoes, Cristina y Morgan-Foster, Jason, “Rainbow Warrior, The” (2010), en *Max Planck Encyclopedia of Public International Law*, <http://www.mpepil.com>, párr. 16.

125 Malanczuk, Peter, *Akehurst's Modern Introduction to International Law*, Routledge Press, Londres, 7.ª edic., 1997, p. 98.

126 *Ibid.*, p. 99. El laudo es del 30/09/1987. Ver también *Greenpeace Press Release*, 02/10/1987.

127 Rysman, Philippe, “Organizaciones no gubernamentales: un actor indispensable de la ayuda humanitaria”, *International Review of the Red Cross*, n.º 865 (marzo de 2007), p. 7.

128 Rosenne, Shabtai, *The Perplexities of Modern International Law*, Martinus Nijhoff, Leiden/Boston, 2004, p. 270.

129 Treves, Tullio, *Civil Society, International Courts and Compliance Bodies*, Cambridge University Press, Cambridge, 2005, p. 4.

Ciudad del Vaticano¹³⁰. Como señala Siotto-Pintor, entonces debemos analizar la subjetividad de la Iglesia Católica y la Santa Sede por un lado, y la de la Ciudad del Vaticano por el otro¹³¹.

Barberis explica que la Iglesia Católica es la comunidad de todos los fieles, cuyo jefe es el Sumo Pontífice. La Santa Sede está constituida por el Papa y por las diversas instituciones que constituyen el gobierno de la Iglesia. Es la autoridad central y el órgano administrativo de la Iglesia. Al examinar la organización de la Iglesia y el contenido de las normas internacionales que obligan a este sujeto, la Iglesia Católica aparece como una comunidad cuyos órganos de gobierno están representados por la Santa Sede. En tal sentido, el sujeto del derecho internacional es la Iglesia Católica, y no la Santa Sede, que actúa meramente como órgano de esta¹³². Por lo tanto, el sujeto del ordenamiento jurídico internacional es la Iglesia Católica y el órgano que lo representa en el plano internacional es la Santa Sede, cuya cabeza es el Sumo Pontífice. Como sujeto del derecho internacional, y en virtud del reconocimiento efectuado por la comunidad internacional, la Iglesia Católica goza de los derechos de legación y celebración de tratados —que en el caso particular se llaman “concordatos”—. En este sentido, la Iglesia Católica constituye un sujeto *sui generis* del ordenamiento jurídico internacional, pues su misión es básicamente de orden religioso y moral¹³³.

Cabe destacar, sin embargo, que en las Naciones Unidas la “Santa Sede” es la entidad que figura con estatus de observador (“Misión Permanente de Observación”) en dicho organismo.

Distinta es la cuestión relativa a la subjetividad de la Ciudad del Vaticano. En 1929, la Iglesia Católica y el Reino de Italia suscribieron los Pactos de Letrán¹³⁴ poniendo fin a la “cuestión romana”, creándose así la Ciudad del Vaticano. Barberis refiere que su creación tuvo por fin asegurar a la Iglesia una absoluta independencia en el cumplimiento de sus fines y garantizarle una soberanía exclusiva e indiscutida en el ámbito internacional¹³⁵. Algunos autores consideran a la Ciudad del Vaticano como un micro-Estado¹³⁶, mientras otros niegan tal posibilidad. Para los que lo consideran un Estado, la Ciudad del Vaticano sería el Estado más pequeño del mundo, que ocupa tan solo 44 hectáreas y tiene una población no permanente de aproximadamente 1000 personas. Su razón de existir es la de proveer una base territorial para la administración de la Iglesia Católica, tal como señaláramos antes. Estas características han llevado a varios autores a señalar que la Ciudad del Vaticano no existe como Estado¹³⁷.

La situación de la Ciudad del Vaticano es peculiar en el ordenamiento jurídico internacional. En primer lugar, por una cuestión histórica. Hasta 1870, los Estados Pontificios constituían uno de los Estados Europeos —con las respectivas características de población, territorio y gobierno a cargo del Santo Padre—. En ese sentido, el papa acumulaba los dos caracteres de jefe espiritual de la Iglesia Católica y jefe político de estos territorios. Luego de 1870, y la anexión por parte del Reino de Italia de los Estados Pontificios, el papa cesa en su carácter de jefe político de territorio alguno, hasta que el 11 de febrero de 1929 se le concede el territorio correspondiente a la Ciudad del Vaticano. Entonces, a partir de los Pactos de Letrán, para algunos juristas la Ciudad de Vaticano constituye un sujeto del ordenamiento jurídico internacional sin perjuicio de la subjetividad independiente de la Iglesia Católica¹³⁸. Pero asimismo, y en segundo lugar, si nos enfocamos en los requisitos que mencionáramos en el apartado correspondiente a los Estados, la Ciudad del Vaticano cuenta con población, territorio y gobierno, a cargo de la Santa Sede, elementos que tiene cualquier Estado. Si bien las condiciones para ser considerado Estado que impone el derecho internacional se encuentran cumplidas marginalmente, el reconocimiento efectuado por la comunidad de Estados parece determinante a la

130 Barberis cita tres concordatos concluidos entre la Santa Sede y España (1953), República Dominicana (1954) y Venezuela (1964); Barberis, Julio, *op. cit.*, p. 169.

131 Siotto Pintor, Manfredi, “Les sujets du droit international autres que les Etats”, *R.C.A.D.I.*, vol. 41 (1932), p. 320.

132 Armas Pfärter, Frida; Barberis, Julio y Querol, María, *op. cit.*, pp. 72-74.

133 CERD/C/266/ADD. 6, 15/02/1998, UN Committee on the Elimination of Racial Discrimination, Remarks.

134 Constan de un concordato y un tratado, y este tiene cuatro anexos.

135 Armas Pfärter, Frida, Barberis, Julio y Querol, María, *op. cit.*, p. 75.

136 Grant, Thomas, *op. cit.*, párr. 1.

137 Arangio-Ruiz, *Annuaire de l'Institut de Droit International, R.B.D.I.*, vol. 29, pp. 366-367, citado en Crawford, James, *The Creation of States in International Law*, Clarendon Press, Oxford, 2.ª edic. 2006, p. 225.

138 Crawford, James, *The Creation of States in International Law*, *op. cit.*, pp. 221-223.

hora de convalidar la existencia de este micro-Estado, tal como señala Crawford¹³⁹. La Ciudad del Vaticano goza de soberanía territorial sobre el espacio asignado por el Pacto de Letrán y sobre el ejercicio exclusiva autoridad legislativa y jurisdicción civil y criminal. Asimismo es parte de la Unión Postal Universal y de la Unión Internacional de Telecomunicaciones, entre otros tratados internacionales.

En síntesis, la Iglesia Católica es la comunidad de fieles; la Santa Sede, su órgano de gobierno, y la Ciudad del Vaticano, el asiento territorial. Para algunos autores, la Iglesia Católica es el sujeto del derecho internacional, aunque las relaciones internacionales se lleven a cabo visualmente a través de la Santa Sede. Para otros, el verdadero sujeto del ordenamiento internacional es la Santa Sede, al igual que la Ciudad del Vaticano —esta última considerada incluso por ciertos juristas como un verdadero Estado—. Como puede observarse, no hay una posición unánime en la doctrina sobre este tema, si bien en los organismos y conferencias internacionales es la “Santa Sede” la que figura como participante.

3.7.2. La Soberana Orden de Malta

La Soberana Orden de Malta (o Soberana Orden Militar de Malta) es una entidad independiente y soberana considerada un sujeto de derecho internacional, único en su especie¹⁴⁰.

Se trata de una Orden de caballeros que tiene su origen en el siglo XI, cuando se crea en Jerusalén una iglesia, un convento y un hospital. La comunidad monástica que dirige el hospital —Orden de San Juan de Jerusalén— se hizo independiente y, por medio de una bula papal, en 1113 se transformó en una orden laica religiosa, bajo la tutela de la Iglesia Católica. Todos los Caballeros eran religiosos y hacían votos de pobreza, castidad y obediencia. La Orden cumplía una función hospitalaria y, durante las cruzadas, asumió la defensa militar de los enfermos y peregrinos¹⁴¹.

En virtud de decretos pontificios, la Orden llegó a ser independiente de cualquier Estado o autoridad y a tener territorio propio. En 1291 se estableció en Chipre. En 1310 los Caballeros adquirieron la Isla de Rodas y transfirieron allí la sede de la Orden. En ese momento tenía una flota propia, con la cual defendía la cristiandad. “La Orden estaba gobernada por el Gran Maestre (Príncipe de Rodas) y por el Consejo, acuñaba moneda y mantenía relaciones diplomáticas con otros Estados”¹⁴². En 1523, los Caballeros fueron derrotados en combate y obligados a retirarse de Rodas. Luego de varios años sin territorio, en 1530 por medio de una cesión, la Orden tomó posesión de la Isla de Malta, donde permaneció hasta 1798, cuando Napoleón Bonaparte la ocupó. Durante su paso por tales territorios, la Orden construyó numerosas iglesias, escuelas de medicina y hospitales, especializándose en oftalmología y farmacología.

Luego de diversas residencias temporarias, la Orden se estableció en Roma, donde actualmente se encuentra su sede. Sin embargo, no volvió a recuperar un territorio propio.

El nombre oficial es Soberana y Militar Orden Hospitalaria de San Juan de Jerusalén de Rodas y de Malta, aunque por razones de conveniencia práctica, comúnmente se la designa con un nombre abreviado. Los caballeros que la integran han sido denominados de diversa manera a través de la historia: caballeros de San Juan —en honor a su patrono—, caballeros de Rodas y caballeros de Malta —en razón de los asientos territoriales en los cuales estuvo la Orden durante algunos períodos—.

Hoy en día la Orden se define como neutral, imparcial y apolítica. Posee un gobierno propio (el príncipe soberano es el Gran Maestre, quien gobierna junto al Soberano Consejo) y un poder judicial (Tribunales Magistrales de Primera Instancia y Apelación). La Orden se rige por el derecho melitense (posee una Carta constitucional y un Código), expide sus propios pasaportes, emite sellos y acuña monedas. La Orden no cumple funciones militares, sino que se ocupa de prestar fundamentalmente asistencia médica y hospitalaria en diversos países del mundo,

139 *Ibid.*

140 Ver De Fisher, H., “L'Ordre Souverain de Malte”, *R.C.A.D.I.*, vol. 163 (1979), pp. 1-48.

141 Cfr. página web de la Soberana Orden de Malta (<http://www.orderofmalta.int>).

142 *Ibid.*

aunque también se involucra en acciones humanitarias y caritativas. Asimismo, puede actuar como mediadora entre Estados y como potencia protectora sustituta en conflictos armados¹⁴³.

La Soberana Orden de Malta mantiene relaciones diplomáticas y posee embajadas en más de cien países, así como misiones permanentes de observación en algunas organizaciones internacionales, tales como las Naciones Unidas, el ACNUR, la OMS, entre otras. Los Estados le reconocen al Gran Maestre las mismas prerrogativas, inmunidades y honores que a los jefes de Estado.

En la República Argentina, la Corte Suprema de Justicia de la Nación tuvo ocasión de reconocer la personalidad internacional de esta entidad en el caso *Radziwill*¹⁴⁴, en el cual interpretó que el actual artículo 117 de la Constitución Nacional (antes de la reforma de 1994 era el 101), cuando hace referencia a que dicho tribunal tiene jurisdicción originaria en "todos los asuntos concernientes a embajadores, ministros y cónsules extranjeros", comprende en la actualidad a los embajadores no solo de Estados extranjeros, sino de otras entidades que, como la Soberana Orden Militar de Malta, mantienen relaciones diplomáticas con la República Argentina. En ese marco, sostuvo lo siguiente:

3º) [...] es innegable que, además de los Estados extranjeros, existen otros sujetos del derecho internacional con quienes la República Argentina mantiene relaciones diplomáticas y cuyos agentes, además de gozar inmunidad, tienen rango diplomático. [...]

7º) Que en el decreto N° 26.589/48 se reconoce a la Soberana Orden Militar de Malta como entidad internacional independiente y se establecen relaciones diplomáticas entre ella y la República Argentina. El carácter de sujeto de derecho internacional de la Orden de Malta es ampliamente reconocido, pudiendo, entre otras cosas, concluir tratados, establecer relaciones diplomáticas, extender pasaportes y empleándose para su Gran Maestre el mismo ceremonial que para un jefe de Estado extranjero [...].

La Soberana Orden de Malta mantiene intensas relaciones con Italia, con quien ha celebrado acuerdos internacionales. A través de diversas sentencias, la Corte Suprema italiana le reconoció a la Orden inmunidades de jurisdicción y en materia impositiva¹⁴⁵.

En el 2000, la Orden celebró un acuerdo con Malta, por medio del cual se le concedió el uso exclusivo por 99 años del Fuerte de San Angelo —que otrora le había pertenecido—, así como una serie de inmunidades y prerrogativas¹⁴⁶.

3.7.3. El Comité Internacional de la Cruz Roja

El Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) es una organización imparcial, neutral e independiente, de carácter *sui generis*¹⁴⁷, fundada en 1863 por iniciativa de un grupo de ciudadanos suizos¹⁴⁸. Uno de ellos, Henry Dunant, luego de presenciar las consecuencias de la sangrienta batalla de Solferino, que tuvo lugar en el norte de Italia, y al observar la desorganización en torno a la asistencia a los soldados heridos y enfermos, así como respecto de los muertos de ambas partes, se propuso la creación de una organización privada en cada país para prestar asistencia en similares situaciones, así como la adopción de un tratado internacional que protegiera a los combatientes fuera de combate y garantizara la neutralidad del personal médico durante el conflicto armado¹⁴⁹. Así, se estableció en 1863 el Comité Internacional de Socorros

143 Gassoni, Francesco, "Malta, Order of" (2008), en *Max Planck Encyclopedia of Public International Law*, <http://www.mpepil.com>, párr. 35.

144 Caso 98, L.XXIV, OSJN, Sentencia, 18/05/1998.

145 Gassoni, Francesco, *op. cit.*, párr. 17.

146 *Ibid.*, párr. 18.

147 Si bien por su modo de creación (bajo el derecho interno de un Estado) y composición (no gubernamental o estatal), el CICR calificaría como una ONG, resulta más preciso referirse a ella como una organización *sui generis*, dado que su personería jurídica no se corresponde *stricto sensu* con la de una ONG.

148 Los cinco ciudadanos suizos eran Henry Dunant, Henry Dufour, Gustave Moynier, Louis Appia y Théodore Maunoir.

149 Gasser, Hans-Peter, "International Committee of the Red Cross (ICRC)" (2013), en *Max Planck Encyclopedia of Public International Law*, <http://www.mpepil.com>, párr. 2.

Mutuos, que luego pasó a denominarse Comité Internacional de la Cruz Roja. En 1864, en una conferencia internacional convocada por Suiza, se adoptó en Ginebra el mentado convenio¹⁵⁰.

El CICR no debe confundirse con las Sociedades Nacionales de la Cruz Roja (o de la Media Luna Roja). Tampoco con el denominado "Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja"¹⁵¹, del cual el CICR es su órgano fundador.

El CICR tiene la misión principal de proteger y brindarles asistencia a las víctimas de los conflictos armados y de ciertas situaciones de violencia interna, así como de promover el derecho internacional humanitario.

Además, para cumplir con sus funciones, establece delegaciones en distintos países del mundo y celebra acuerdos de sede con dichos Estados, a fin de que se le reconozca personalidad jurídica internacional e inmunidad de jurisdicción¹⁵² y se les confiera a sus delegados las mismas inmunidades y privilegios de los que gozan los representantes de las organizaciones internacionales gubernamentales.

A diferencia del resto de las organizaciones no gubernamentales, el CICR tiene facultades que le han sido conferidas por los Estados a través de tratados internacionales. En efecto, los cuatro Convenios de Ginebra de 1949 y los Protocolos Adicionales se refieren al CICR en varios artículos, como se verá en el capítulo 46 de esta obra.

Asimismo, en el marco de la Corte Penal Internacional, también se le reconoció un estatus especial al CICR en las Reglas de Procedimiento y Prueba, puesto que se previó que, salvo excepciones explícitamente consideradas en dicha regla, "La Corte considerará privilegiados y, en consecuencia, no sujetos a divulgación, incluso por conducto del testimonio de alguien que haya sido o sea funcionario o empleado del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), la información, los documentos u otras pruebas que lleguen a manos de ese Comité en el desempeño de sus funciones con arreglo a los Estatutos del Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja o como consecuencia del desempeño de esas funciones [...]"¹⁵³.

Por último, cabe destacar que la Asamblea General de las Naciones Unidas —así como también lo han hecho otros organismos internacionales— le ha otorgado estatus de observador en dicha organización, a través de una resolución especial¹⁵⁴.

Todas estas particularidades hacen que el CICR, aunque haya sido creado bajo el derecho suizo y esté integrado por individuos, sea un sujeto especial, único, que debe ser diferenciado de las organizaciones no gubernamentales en general¹⁵⁵.

4. Categorías en discusión

Existen algunos conceptos que son objeto de discusión entre los juristas y académicos respecto de si constituyen sujetos del derecho internacional, actores o no califican como ninguno de ellos. Tal el caso de los pueblos indígenas, la sociedad civil, la humanidad y/o las generaciones futuras, entre otros.

A continuación nos referiremos en particular a algunas de ellas: los pueblos indígenas, la sociedad civil y la humanidad y/o las generaciones futuras.

150 Convenio de Ginebra para el mejoramiento de la suerte que corren los militares heridos en los ejércitos en campaña, 22/08/1864.

151 El Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja está formado por las Sociedades Nacionales —por ejemplo la Cruz Roja Argentina—, el CICR y la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja. Todos ellos se reúnen —generalmente cada cuatro años— junto con los Estados parte de los Convenios de Ginebra en la "Conferencia Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja". Se trata de un foro de diálogo y discusión sobre distintos problemas que atañen al derecho internacional humanitario y otras cuestiones de esta índole. En ella se evalúan las propuestas presentadas referidas a la revisión de los Convenios de Ginebra y sus protocolos y a otros convenios de derecho internacional humanitario.

152 De esta forma el CICR se protege contra procedimientos administrativos y judiciales en el Estado en el que se encuentra la delegación y garantiza la inviolabilidad de sus locales, archivos y documentos.

153 Regla 73(4) de Procedimiento y Prueba.

154 Resolución 45/8 de la Asamblea General, 18/10/1990.

155 Gasser, Hans-Peter, *op. cit.*, párrs. 25-26.

4.1. Los pueblos indígenas/originarios

Se ha planteado la posibilidad de considerar a los pueblos indígenas u originarios como sujetos del derecho internacional debido a que existen tratados internacionales que les otorgan derechos específicos. Mientras que algunos autores en la actualidad están a favor de ello¹⁵⁶, otros consideran que "en el futuro" los pueblos indígenas podrían calificar como sujetos del derecho internacional¹⁵⁷.

Lo cierto es que existen varios instrumentos internacionales que confieren derechos específicos a los pueblos indígenas. En el marco de la Organización Internacional del Trabajo, podemos mencionar, en particular, los Convenios 107 y 169.

El Convenio 107 sobre Pueblos Indígenas y Tribales constituyó un primer intento de codificar las obligaciones internacionales de los Estados en relación con los pueblos indígenas y tribales. Como consecuencia del desarrollo del derecho internacional de los derechos humanos, el Convenio 169 surgió como una revisión del mentado Convenio 107. El Consejo de Administración de la OIT convocó a una Comisión de Expertos en 1986 que concluyó que el "enfoque integracionista del Convenio estaba obsoleto y que su aplicación era perjudicial en el mundo moderno"¹⁵⁸. Así, la OIT señala tres diferencias fundamentales entre los dos convenios mencionados. Mientras que el Convenio 107 se funda en el supuesto de que los pueblos indígenas y tribales eran sociedades temporarias destinadas a desaparecer con la modernización, el Convenio 169 lo hace en la creencia de que los pueblos indígenas constituyen sociedades permanentes. Asimismo, el primero refiere a las "poblaciones indígenas y tribales", mientras que el último hace referencia a "pueblos indígenas y tribales". Por último, el objeto del Convenio 107 era fomentar la integración, mientras que el Convenio 169 reconoce y respeta la diversidad étnica y cultural¹⁵⁹. Lo importante es señalar que este segundo convenio no solo establece obligaciones para los Estados parte, sino que también dispone derechos de manera directa para los pueblos indígenas y tribales.

Ahora bien, ninguno de los dos convenios define a "los pueblos indígenas y tribales". El Convenio 169 aporta varios criterios prácticos para determinar cuáles pueden ser considerados como indígenas y entre estos elementos menciona los siguientes: estilos tradicionales de vida, cultura y modo de vida diferentes de los otros segmentos de la población nacional, organización social e instituciones políticas propias, y vivir en continuidad histórica en un área determinada¹⁶⁰. El mismo procedimiento realiza para los pueblos tribales¹⁶¹. Precisamente su definición constituye uno de los principales problemas con que nos encontramos a la hora de analizar la subjetividad internacional de dicho grupo. El mayor inconveniente radica en distinguir a los pueblos indígenas de otros conceptos más amplios como el de pueblos o incluso el de minorías, tal como están desarrollados en el derecho internacional¹⁶². Sin embargo, la situación de vulnerabilidad en que los pueblos indígenas se encuentran frente a los Estados ha ameritado el desarrollo de normas internacionales especiales destinadas a protegerlos.

En el marco de la ONU, un importante hito se produjo el 10 de diciembre de 2007, con la adopción por parte de la Asamblea General de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas¹⁶³. Este instrumento fue adoptado por una mayoría de 143 Estados a favor, 4 votos en contra (Australia, Canadá, Nueva Zelanda y Estados Unidos de América) y 11 abstenciones (Azerbaiyán, Bangladesh, Bután, Burundi, Colombia, Georgia, Kenia, Nigeria, Rusia, Samoa y Ucrania). La Declaración establece un marco universal de es-

tándares mínimos para la dignidad, bienestar y derechos de los pueblos indígenas del mundo y fue el resultado de más de dos décadas de negociaciones entre los gobiernos y los representantes de los pueblos indígenas. Sin perjuicio del carácter no vinculante de la Declaración, el gran número de votos a favor, como la práctica de los Estados con relación a los derechos indígenas, permite afirmar que nos encontramos ante el surgimiento de nuevas normas consuetudinarias que protejan a las comunidades indígenas.

En los ámbitos regionales, la afirmación de que hoy en día los pueblos indígenas pueden ser considerados como sujetos del ordenamiento jurídico internacional parece más clara. Por ejemplo, en el Sistema Africano se ha adoptado la Carta Africana sobre los Derechos Humanos y de los Pueblos, que en sus artículos 19 a 24 establece derechos a los pueblos que habitan el continente africano¹⁶⁴.

Por su parte, la Organización de Estados Americanos y otros órganos del Sistema Interamericano aún continúan trabajando en el proyecto de una Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas¹⁶⁵. Sin embargo, el reconocimiento de los derechos indígenas se ha producido a partir de decisiones tanto de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos como de la Corte Interamericana de Derechos Humanos¹⁶⁶. Para mencionar algunos ejemplos, podemos referirnos a los derechos reconocidos por la Corte Interamericana en dos de sus sentencias, como son los casos de *Comunidad Mayagna Awas Tingni c. Nicaragua* y *Comunidad Indígena Xámkoc Kásek c. Paraguay*. En la primera de ellas, la Corte reconoce el derecho de propiedad comunal de los pueblos indígenas al señalar que "el artículo 21 de la Convención [Americana sobre Derechos Humanos] protege el derecho a la propiedad en un sentido que comprende, entre otros, los derechos de los miembros de las comunidades indígenas en el marco de la propiedad comunal. Los indígenas por el hecho de su propia existencia tienen derecho a vivir libremente en sus propios territorios; la estrecha relación que los indígenas mantienen con la tierra debe de ser reconocida y comprendida como la base fundamental de sus culturas, su vida espiritual, su integridad y su supervivencia económica"¹⁶⁷. En la segunda, se reconoció el derecho de reivindicación de las comunidades indígenas respecto a tierras tradicionales¹⁶⁸. A partir de las mentadas decisiones jurisdiccionales, se puede observar cómo la Corte Interamericana, utilizando las normas internacionales vigentes, reconoce expresamente derechos a los pueblos indígenas como tales, confirmando su subjetividad internacional.

Por último, se ha reconocido la posibilidad de que los pueblos indígenas celebren tratados internacionales con Estados¹⁶⁹. Un ejemplo de esto es la Convención Nórdica-Saami¹⁷⁰. Se trata de un acuerdo internacional celebrado entre el pueblo Saami y los gobiernos de Suecia, Noruega y Finlandia, en el cual se reconocen importantes derechos al pueblo indígena Saami. Otros tratados celebrados por comunidades indígenas también han sido reconocidos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, como en el caso *Moiwana c. Suriname*, donde la Corte expresamente señaló:

[...] estas seis comunidades negociaron individualmente tratados de paz con las autoridades coloniales. En 1760 el pueblo Ndjuka firmó un tratado que dispuso su liberación de la esclavitud, un siglo antes de que la esclavitud fuera abolida en la región. En 1837 este tratado fue renovado; los términos del acuerdo permitían a los Ndjuka continuar residiendo en el territorio donde se habían establecido y determinaron los

156 Vukas, Budislav, "States, Peoples and Minorities", R.C.A.D.I., vol. 231 (1991), pp. 491-499; Barsh, Russel Lawrence, "Indigenous Peoples in the 1990s: From Object to Subject of International Law?", *Harvard Human Rights Journal*, vol. 7 (1994), pp. 33-86.

157 Walter, Christian, *op. cit.*, párr. 12; Rosenne, Shabtai, *op. cit.*, p. 271.

158 Informe de la Comisión de Expertos, 1986.

159 Ver <http://www.ilo.org/indigenous/Conventions/no107/lang-es/index.htm>.

160 Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, art. 1(1).

161 *Ibid.*, art. 1(2).

162 Brownlie, Ian, "The Subjects of International Law", en *International Law at the Fiftieth Anniversary of the United Nations: General Course on Public International Law*, R.C.A.D.I., vol. 265 (1995), p. 62.

163 Resolución A/RES/61/295, 10/11/2007.

164 Aprobada el 27/06/1981, durante la XVIII Asamblea de Jefes de Estado y Gobierno de la Organización de la Unidad Africana, reunida en Nairobi, Kenya.

165 La página web del grupo encargado de la tarea es <http://www.oas.org/consejo/sp/CAJP/Indigenas.asp>.

166 Ver al respecto Vuotto, Jonathan, "Awas Tingni v. Nicaragua: International Precedent for Indigenous Land Rights", *Boston University International Law Journal*, vol. 22 (2004), pp. 219-243.

167 *Comunidad Mayagna (Sumo) Awas Tingni c. Nicaragua*, Corte IDH, Sentencia de fondo, reparaciones y costas, 31/08/2001, párrs. 148-149.

168 *Comunidad Indígena Xámkoc Kásek c. Paraguay*, Corte IDH, Sentencia de fondo, reparaciones y costas, 24/08/2010, párrs. 112-116.

169 Alfredsson, Gudmundur, "Indigenous Peoples, Treaties with" (2012), en *Max Planck Encyclopedia of Public International Law*, <http://www.mpepil.com>, párrs. 1-16.

170 Texto disponible en http://www.galdu.org/govat/doc/samekoneng_net.pdf.

límites de ese área. Los Maroons en general –y los Ndjuka en particular– consideran dichos tratados aún válidos y con autoridad respecto de su relación con el Estado, a pesar de que Suriname logró su independencia de Holanda en 1975¹⁷¹.

En consecuencia, y a partir de lo referenciado, parece posible sostener que los pueblos indígenas constituyen hoy en día un sujeto del derecho internacional público, pues existen normas internacionales que les consagran derechos, como asimismo se ha reconocido y aceptado tanto su capacidad de celebrar tratados como la posibilidad de que presenten reclamos ante foros internacionales.

4.2. La sociedad civil

Si bien no contamos con una definición jurídica, la expresión “sociedad civil” es frecuentemente utilizada en derecho internacional para hacer referencia a actores *no estatales* que no cumplen funciones gubernamentales o lucrativas (grupos de personas, ONG, entidades religiosas, asociaciones profesionales académicas, etc.) involucrados activamente en asuntos internacionales (realizan campañas para llamar la atención sobre la necesidad de poner ciertas cuestiones en la agenda de los Estados o de las organizaciones internacionales, participan activamente en conferencias internacionales, ejercen influencia en la adopción de instrumentos internacionales, etc.) de diversa índole (derechos humanos, derecho internacional ambiental, derecho internacional humanitario, derecho internacional penal, etc.)¹⁷².

Como tal, la sociedad civil no se encuentra organizada, sino que es una expresión que engloba a varias clases de actores¹⁷³. No posee personalidad jurídica propia, por lo que no puede ser considerada un sujeto del derecho internacional¹⁷⁴.

4.3. La humanidad y/o las generaciones futuras

Algunos doctrinarios se refieren a la humanidad o a las generaciones futuras como posibles categorías de sujetos del derecho internacional. A continuación nos referiremos a estos conceptos, a los fundamentos que han sido esbozados para justificar su personalidad internacional y a las críticas recibidas.

Existen diversos acuerdos internacionales que se refieren a “la humanidad”, como es el caso del Tratado sobre los Principios que Deben Regir las Actividades de los Estados en la Exploración y Utilización del Espacio Ultraterrestre, incluso la Luna y otros Cuerpos Celestes (1966) que, en su artículo 1, dispone: “La exploración y utilización del espacio ultraterrestre, incluso la Luna y otros cuerpos celestes, deberán hacerse en provecho y en interés de todos los países, sea cual fuere su grado de desarrollo económico y científico, e incumben a toda la humanidad”¹⁷⁵. Asimismo, la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (1982) establece en su artículo 136 que “La Zona y sus recursos son patrimonio común de la

171 *Comunidad Molwani v. Surinam*, Corte IDH, Interpretación de la Sentencia de fondo, reparaciones y costas, 08/03/2006, párrafo 86(2).

172 Stabroek, Gerald, “Civil Society” (2012), en *Max Planck Encyclopedia of Public International Law*, <http://www.mpepil.com>, párrs. 1-5.

173 Al respecto, ver, por ejemplo, Pedraza Farfán, Laura, “Conceptions of Civil Society in International Law Making and Implementation. A Theoretical Framework”, *Michigan Journal of International Law*, vol. 34 (2013), pp. 101-173; Haslam, Emily, “Subjects and Objects. International Criminal Law and the Institutionalization of Civil Society”, *The International Journal of Transitional Justice*, vol. 5 (2011), pp. 221-240; Cakmak Dena, “Civil Society Actors in International Law and World Politics: Definitions, Conceptual Frameworks, Problems”, *International Journal of Civil Society*, n.º 6 (2008), pp. 7-86; Cullen, Holly y Morrow Karen, “International Civil Society in International Law”, *Non-States Actors and International Law Review*, n.º 1, (2001), pp. 7-39, entre otros.

174 *Ibid.*, párr. 7.

175 Tratado sobre los Principios que Deben Regir las Actividades de los Estados en la Exploración y Utilización del Espacio Ultraterrestre, incluso la Luna y Otros Cuerpos Celestes, aprobado por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 19/12/1966, Resolución 2222 (XXI), abierto a la firma en Londres, Moscú y Washington el 27/01/1967, entró en vigor el 10/10/1967, art. 1.

humanidad”¹⁷⁶ y la Convención para la Protección del Patrimonio Mundial Cultural y Natural (1972) también posee disposiciones similares¹⁷⁷. Ello ha llevado a algunos autores a considerarla como un sujeto de derecho internacional¹⁷⁸.

Barberis considera que el análisis de esos textos no permite arribar a la conclusión de que “la humanidad” sea destinataria directa y efectiva de derechos u obligaciones internacionales”, puesto que “una simple declaración o enunciación no es suficiente para erigirla en sujeto de derecho”¹⁷⁹.

A esa misma conclusión arriba Charpentier, quien sostiene que “la humanidad no posee personalidad jurídica internacional, ya que es imposible establecer quiénes son los representantes de los intereses de las generaciones de individuos actuales y futuras a las cuales les pertenece el patrimonio común de la humanidad”¹⁸⁰. Esa es también la línea que han adoptado los doctrinarios más tradicionales¹⁸¹.

Desde otro punto de vista, Daillier, Forteau y Pellet concluyen que, hoy en día, la comunidad internacional –o, más bien, la humanidad– pueden ser considerados sujetos “menores” del ordenamiento jurídico internacional, ya que esta se encuentra representada principalmente por los Estados y las organizaciones internacionales de carácter universal. Sostienen que el derecho internacional se encuentra en vías de un reconocimiento progresivo, lento y prudente de una cierta personalidad jurídica de la humanidad. Estos autores, para arribar a dicha conclusión, consideran en su estudio también al artículo 53 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados (1969) y al artículo 23 del proyecto de la Comisión de Derecho Internacional sobre la Cláusula de la Nación más Favorecida, entre otros¹⁸².

En ese mismo orden de ideas, Cançado Trindade parece dar un paso más al sostener que en la actualidad es imposible negar que la humanidad se haya constituido en un sujeto del derecho internacional, junto con los Estados, los individuos y las organizaciones internacionales, entre otros. Así, remarca que el establecimiento de obligaciones *erga omnes* y normas de *jus cogens* establecen la titularidad de derechos y obligaciones sobre la humanidad en general para la protección no solo de las generaciones presentes, sino también de las generaciones futuras¹⁸³.

Como se observa de la opinión de los doctrinarios mencionados, la cuestión de la subjetividad de la humanidad es sumamente discutida.

En la misma línea, los juristas también han considerado la posibilidad de que las “generaciones futuras” posean subjetividad internacional. La teoría de la justicia intergeneracional tuvo su auge sobre todo a partir de los planteos que realizara John Rawls¹⁸⁴. Al igual que sucede con el concepto de humanidad, la incapacidad por parte de las generaciones venideras de reclamar los derechos que les sean otorgados ha sido el principal obstáculo para reconocerles una personalidad jurídica internacional. Han existido esfuerzos, por ejemplo, por parte de la

176 Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, adoptada el 10/12/1982, entró en vigor el 16/11/1994, art. 136.

177 Adoptada en el marco de la Conferencia General de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, en su 17.ª reunión celebrada en París del 17/10 al 21/11/1972.

178 Marroff, Marco, *Traité de droit international public de l'espace*, Fribourg, Ginebra-Paris-Nueva York, 1973, p. 273 y ss, citado en Barberis, Julio, *op. cit.*, nota al pío 44, p. 177; Cançado Trindade, Antônio Augusto, *O Direito Internacional em um Mundo em Transformação*, Renovar, Rio de Janeiro, 2003, pp. 1068, 1069, 1094-1096, citado en Cançado Trindade, Antônio Augusto, *International Law for Humankind*, Brill, Londres, 2010) p. 276.

179 Barberis, Julio, *op. cit.*, p. 177.

180 Charpentier, Jean, “L'Humanité: un patrimoine, mais pas de personnalité juridique”, en *Les hommes et l'environnement – Etudes e hommage à Alexandre Kiss*, Frison-Roche, Paris, 1998, pp. 17-21, citado en Vukas, Budislav, *op. cit.*, p. 484 (traducción libre).

181 O'Connell, Daniel Patrick, *International Law*, Dobbs Ferry, Londres y Nueva York, 1965, vol. 1, p. 89.

182 Nguyen Quoc Dinh, Daillier, Patrick, Forteau, Mathias y Pellet, Alain, *op. cit.*, pp. 443-446. La misma idea es sostenida por Halajcsuk, quien entiende que la humanidad es un sujeto parcial del derecho internacional; Halajcsuk, Bohdan y Moya Domínguez, María Teresa del Rosario, *Derecho Internacional Público*, 3.ª edic., Ediar, Buenos Aires, 1999, p. 169.

183 Cançado Trindade, Antônio Augusto, *International Law for Humankind: Towards a New Jus Gentium*, Martinus Nijhoff, Leiden/Boston, 2.ª edic., 2012, p. 278.

184 Rawls, John, *A Theory of Justice*, Library of the Congress, Washington D.C., 1971.

Soberana Orden de Malta, de crear una suerte de *ombudsman* o defensor de los intereses de las generaciones venideras en el marco de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo que resolvería el inconveniente señalado¹⁸⁵. Sin embargo, tal propuesta no tuvo favorable acogida en el marco referenciado y hoy en día no existe una figura de similares características en el ordenamiento jurídico internacional.

Es en ese sentido que nuevamente nos encontramos imposibilitados de resolver de manera acabada la cuestión de la existencia de una personalidad jurídica internacional de las generaciones futuras. Tal calificación dependerá, en última instancia, de la definición de sujeto del derecho internacional que se adopte y de los elementos que se exijan para que los entes encuadren dentro de tal categoría.

CAPÍTULO 3

LAS NACIONES UNIDAS

Sergio Alejandro Rojo

1. La Organización de las Naciones Unidas: antecedentes

Con el fin de la Primera Guerra Mundial, las potencias vencedoras, sobre todo los Estados Unidos, buscaron crear una institución basada en la democracia: una organización mundial que funcionara bajo el imperio de la ley¹. Esa era la idea rectora del entonces presidente de los Estados Unidos, Woodrow Wilson, quien creía que con el fin de la guerra surgiría una revolución democrática en todo el mundo, y sería necesaria una organización internacional que la garantizara.

En ese sentido, en 1919 surgió la primera organización internacional gubernamental, la Sociedad de las Naciones –o Liga de las Naciones–², con competencias generales, que pretendía “fomentar la cooperación entre las naciones y garantizar la paz”³.

Sin embargo, la ambiciosa idea de Wilson fracasó prácticamente desde sus inicios, sobre todo porque el Senado de los Estados Unidos no aprobó la ratificación del tratado, impidiendo el ingreso de su principal promotor como miembro de la Sociedad de las Naciones. Asimismo, la falta de una prohibición al uso de la fuerza dio lugar a invasiones y anexiones de territorio (la invasión japonesa a Manchuria, la invasión soviética de Finlandia y la invasión italiana a Etiopía), lo que debilitó gravemente su posición como garante de la paz.

Para 1939 la mayoría de los miembros se habían retirado de la Sociedad de las Naciones o habían sido expulsados, dejándola virtualmente inoperante. Su final fue determinado por el estallido de la Segunda Guerra Mundial.

Ya durante este conflicto se evidenció la necesidad de contar con un sistema de seguridad colectiva más amplio y permanente, abierto a todos los Estados, como también de una nueva organización internacional de carácter general. Así fue que, al firmar la Carta del Atlántico, el 14 de agosto de 1941, el presidente Roosevelt y el primer ministro británico Churchill incluyeron ocho puntos que delinearon los objetivos que debería contener la próxima organización internacional. Estos puntos fueron luego replicados en la Declaración de las Naciones Unidas –o Declaración de Washington– del 1 de enero de 1942, suscripta por las veintiséis naciones aliadas, que sentó las bases sobre las que habría de sustentarse el nuevo orden mundial.

A la Declaración de las Naciones Unidas le siguió la Declaración de Moscú, del 30 de octubre de 1943, que fue firmada por las cuatro grandes potencias: Estados Unidos, Rusia, China y Gran Bretaña. Estos países manifestaron su intención de perpetuar la alianza más allá del conflicto bélico que la motivó. Con ese objetivo se firmó la Declaración de Teherán, el 1 de diciembre de 1943, donde se determinó la creación de los comités de expertos. Estos com-

1 Ikenberry, G. John, *After Victory*, Princeton University Press, New Jersey, 2001, p. 127.

2 Al respecto, ver Tam, Christian, “League of Nations” (2009), en *Max Planck Encyclopedia of Public International Law*, <http://www.mpeil.com>.

3 Pacto de la Sociedad de las Naciones, 28/06/1919, preámbulo.